GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Educação

ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - EEEP

ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CURSO TÉCNICO EM SECRETARIADO

DIREITO E LEGISLAÇÃO

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Educação

Governador
Cid Ferreira Gomes

Vice Governador
Domingos Gomes de Aguiar Filho

Secretária da Educação
Maria Izolda Cela de Arruda Coelho

Secretário Adjunto
Maurício Holanda Maia

Secretário Executivo
Antônio Idilvan de Lima Alencar

Assessora Institucional do Gabinete da Seduc
Cristiane Carvalho Holanda

Coordenadora da Educação Profissional – SEDUC
Andréa Araújo Rocha

SUMÁRIO

1. Introdução ao Estudo do Direito

1.1. Conceito básico de Direito e noção de norma jurídica;

1.2. Principais ramos do Direito;

1.3. Hierarquia das normas jurídicas;

1.4. Antinomia entre normas e solução de conflitos;

1.5. Questões;

2. Noções de Direito Constitucional

2.1. Direito Constitucional;

2.2. Constituição: conceito, classificação e história;

2.3. Poder Constituinte

2.4. Princípios fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil;

2.5. Direitos e garantias fundamentais;

2.6. Organização do Estado.

2.7. Questões;

3. Direito Administrativo

3.1. Conceito de Direito Administrativo;

3.2. Administração pública;

3.2.1. Regime jurídico-administrativo

3.2.2. Organização da Administração Pública

3.3. Atos Administrativos;

3.4. Serviços públicos;

3.5. Servidores públicos.

3.6. Questões.

4. Direito Empresarial

4.1. Breve evolução histórica do Direito Empresarial

4.2. Conceito de Empresário

4.2.1. Agentes econômicos excluídos do conceito de empresário

4.3. Empresário individual

4.4. Principais Sociedades Empresárias

4.4.1. Sociedade limitada

4.4.2. Sociedade anônima

4.5. Direito de propriedade industrial

4.6. Questões

5. Direito Civil

5.1. Parte Geral do Código Civil

5.1.1. Pessoa

5.1.2 Bens

5.1.3 Fatos, atos negócios jurídicos

5.1.4. Prescrição e decadência

5.2. Questões

6. Direito do Consumidor

6.1. Dos direitos básicos do consumidor
6.2. Da qualidade de produtos e serviços; Da prevenção e reparação de danos
6.2.1. Proteção à saúde e segurança
6.2.1.1. Responsabilidade pelo fato do produto e do serviço
6.2.1.2. Responsabilidade pelo vício do produto e do serviço
6.3. Das práticas abusivas
6.4. Da proteção contratual
6.5. Questões

1. Introdução ao Estudo do Direito

1.1. Conceito básico de Direito e noção de norma jurídica

Etimologicamente, Direito vem do latim “directus”, que se refere a “seguir regras pré-determinadas ou um dado preceito”.

Inúmeros filósofos, desde os tempos da Grécia Antiga – passando pelos filósofos romanos, iluministas, positivistas, liberais, socialistas, neoconstitucionalistas ou pós-positivistas, dentre tantos outros – tentaram cunhar o conceito de Direto, reunindo elementos que serviram para atingir a sua acepção moderna.

É certo que a palavra “direito” possui diferentes acepções, a saber:

a) **sistema de normas de conduta** imposto à coletividade por um conjunto de instituições, que são responsáveis por regular as relações sociais.

Este conjunto de normas é dotado de **coercitividade**, que consiste na capacidade que a norma tem impor aos indivíduos determinadas condutas.

Existem normas que, se desrespeitadas, podem ter sua coercitividade efetivada mediante a **coação-sanção**. Esta consiste em exigir, concretamente, a realização de determinada conduta. EX: É proibido matar outrem. Trata-se de uma norma coercitiva, que impõe ao indivíduo um dever de não tolher determinado bem de outro sujeito de direito. Caso o faça, o Estado deve agir coativamente para punir quem desrespeitou a norma, de modo a punir e ressocializar o indivíduo, mostrando à sociedade que a conduta praticada não é correta e deve ser reprimida.

É importante salientar que todas as normas possuem coercitividade, ensejando um imperativo ao indivíduo, mas nem toda norma enseja uma coação-sanção por parte do Estado. Algumas normas, por exemplo, tem conteúdo meramente interpretativo das demais normas.

b) Sistema de normas de um determinado país. EX: O Direito Brasileiro condena a pena de morte;

c) Normas de um determinado ramo do direito. EX: O Direito Administrativo Brasileiro não está reunido em uma codificação.

d) A palavra “direito” também é utilizada para indicar direito subjetivo. EX: João tem direito de entrar em juízo para pleitear a guarda do filho.

e) Direito também é utilizado para indicar a “ciência do direito”, ou seja, o ramo da ciência que estuda o conjunto normativo e o modo como regula as relações sociais. EX: Sérgio tem que estudar bastante direito para passar em um concurso público.

Atualmente, a concepção de Direito mais difundida pela doutrina foi estabelecida por Miguel Reale, criador da “teoria Tridimensional do Direito”.

Este doutrinador sempre criticou a posição de que o Direito estava vinculado unicamente à atividade do legislador, como idealizou Hans Kelsen, em seu sistema de subsunção clássica.

Tal sistema defende que um fato jurídico surge a partir do enquadramento do fato concreto ao conceito abstrato contido na norma, sem qualquer análise valorativa.

Reale, ao revés, criou um sistema de subsunção moderna (teoria tridimensional do direito),

sustentando que o aplicador do Direito deve ater-se a três subsistemas isomórficos entre si: fato, valor e norma.

São sistemas independentes, mas que se relacionam para a definição do Direito.

Tratam-se de sistemas abertos – representados graficamente por três semi-círculos concêntricos – **sempre sujeitos a alterações**. O Direito seria algo em constante dinamismo. Daí porque não se pode ter um apego tão intenso ao que está disposto na norma.

Em suma, o autor mencionado entende que não se determina o que é Direito olhando apenas o fato e a norma jurídica. **O que muda na subsunção moderna, em relação à clássica, é que o aplicador passou a analisar valores**.

A referência de Miguel Reale é **Direito Democrático**.

O Direito é um dado em constante construção pela sociedade. A idéia do Direito Democrático se acopla a idéia de evolução da norma jurídica.

1.2. Principais ramos do Direito

A divisão do Direito em ramos é meramente didática, já que o Direito é considerado uno e sua interpretação, integração e aplicação dependem de uma análise sistêmica.

Eis os principais ramos do Direito:

a) Direito Constitucional: tem como objeto de estudo a teoria da constituição e os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil. Sua análise é primordial, uma vez que a Constituição é o fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico.

Neste ramos, faz-se uma análise do constitucionalismo em seus primórdios até os seus contornos atuais.

Ademais, busca-se pormenorizar as matérias constitucionais, como direitos fundamentais, organização do Estado e organização dos Poderes.

b) Direito Administrativo: “Conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado” (HELY LOPES MEIRELES).

Em suma, estuda a atuação estatal enquanto Administração Pública e sua relação com o administrado. Exclui-se deste ramo a atuação do Estado na realização de políticas públicas.

c) Direito Civil: trata-se do sistema de normas que rege as relações entre particulares (relação horizontal).

Ressalte-se que o Direito Civil está submetido a normas cogentes. Trata-se de um fenômeno chamado “publicização do Direito Civil”, vez que o Estado não pode deixar todas as relações ao alvedrio dos particulares, devendo estabelecer limites essenciais à sadia convivência entre os sujeitos de direito.

Atualmente, ressalta-se que até os direitos fundamentais são extensíveis ao setor privado, mediante a adoção da denominada “horizontalização dos direitos fundamentais” (expressão adotada pelo Supremo Tribunal Federal).

d) Direito Penal: Estabelece tipos penais que, se infringidos, geram uma sanção penal.

Ressalte-se que o Direito Penal só deve resguardar bens de extrema importância, que não seriam efetivamente albergados pelo ordenamento se estivessem afetos aos demais remos.

e) Direito Processual (civil e penal): São os ramos responsáveis por criar regras procedimentais que darão efetividade ao Direito material.

f) Direito Tributário: Tem como objeto de estudo os tributos, as limitações constitucionais ao dever de tributar e as regras do Código Tributário Nacional atinentes à matéria.

g) Demais ramos: Existem inúmeros outros ramos do Direito com seus objetos definidos – Direito Previdenciário (estuda as normas sobre seguridade social, custeio e concessão de benefícios), Direito Eleitoral (estuda as normas sobre processo eletivo, ações eleitorais e inelegibilidades), Direito Empresarial (estuda a atividade empresarial como um todo), Direito Ambiental (estuda a relação do homem com o meio-ambiente, estabelecendo conceitos sobre questões ambientais e proibindo a realizações de atividades que possam comprometer a biosfera), dentre tantos outros ramos.

1.3. Hierarquia das normas jurídicas

As normas jurídica estão submetidas a uma hierarquia, que foi idealizada por Hans Kelsen, doutrinador austríaco responsável pela idealização da denominada **"pirâmide kelseniana"**.

No topo da pirâmide, está a Constituição Federal, norma hierárquica de maior valor e que deve nortear a criação de todas as demais normas. Estas, por sua vez, devem obediência à Constituição Federal, e não podem contrapô-la, sob pena de serem extirpadas do ordenamento jurídico.

A hierárquica constitucional foi aprimorada por Konrad Hesse, que idealizou a "supremacia da constituição", sendo primordial para a idealização sistema concreto de controle de constitucionalidade (este controle visa analisar a compatibilidade, em abstrato, entre as normas infraconstitucionais e a Constituição).

Mais abaixo, no meio da pirâmide, estão as leis – ordinárias, complementares, delegadas e medidas provisórias (baixadas pelo Presidente em casos de relevância e urgência. Tem força de lei), de acordo com a determinação constitucional.

As leis, reitera-se, devem obediência aos dispositivos constitucionais.

Por último, temos os dispositivos administrativos que vêm regulamentar o conteúdo legal, com o escopo de que este possa assumir efeitos concretos. EX: regulamentos, instruções normativas, decretos, portarias, etc.

1.4. Antinomia entre normas e solução de conflitos

Antinomia consiste na contradição entre duas normas, dois princípios ou entre uma norma e um princípio, aplicáveis a uma mesma situação.

Para que ocorra a antinomia, ambas as normas devem ser válidas e vigentes, e as soluções apresentadas devem ser divergentes.

Se as soluções forem convergentes, ambas as normas devem ser aplicadas, segundo a tese do diálogo das fontes, difundida por **Claudia Lima Marques**.

Espécies de antinomia:

a) Antinomia de primeiro e de segundo grau

Antinomia de primeiro grau é aquela resolvida através da aplicação de um único critério de solução de conflitos, dentre os seguintes: a.1) **Cronológico** (prevalece a norma mais nova); a.2) **Especialidade** (prevalece a norma especial em detrimento da geral); a.3) **Hierárquico** (prevalece a norma de maior hierarquia).

Antinomia de segundo grau é aquela em que há um **conflito entre os critérios**. É solucionada

através da aplicação de uma **metacritério.**

Eis as hipóteses:

Conflito entre cronológico e hierárquico – Deve prevalecer o critério hierárquico (metacritério);

Conflito entre o cronológico e o da especialidade – A maioria da doutrina entende que deve prevalecer o critério da especialidade.

Conflito entre o hierárquico e o da especialidade – Em regra, deve prevalecer o critério hierárquico, sob pena de ruptura do sistema jurídico fundamentado na supremacia das leis.

Contudo, excepcionalmente, defende-se que pode prevalecer o critério da especialidade, quando for a solução mais justa para o caso concreto. É o que Maria Helena Diniz denomina princípio supremo da justiça.

b) Antinomia é real e antinomia aparente

Antinomia aparente é aquela em que os critérios para sua solução são normas integrantes do ordenamento jurídico. Toda antinomia de primeiro grau é um exemplo de antinomia aparente.

Antinomia real é aquela em que a situação do aplicador da norma é considerada insustentável em razão de **não existir critério normativo para solucionar a antinomia** ou **existir conflito entre os critérios de solução de antinomia**. Toda antinomia de segundo grau é uma antinomia real.

Ressalte-se que a solução judicial da antinomia real apenas resolve o caso concreto – não elimina a antinomia. O ideal é a solução legislativa, muito embora o surgimento de uma nova lei possa dar origem a uma nova antinomia.

A técnica mais recomendada para a solução de antinomias reais é a da ponderação de valores, analisando-se qual solução está de acordo com os valores que interessam a sociedade naquele momento. OBS: Na dúvida, adotar a solução mais próxima da dignidade da pessoa humana.

1.5. Questões

1ª) Cite três diferentes acepções da palavra direito.

2ª) Explique a diferença entre coercitividade e coatividade.

3ª) O que se entende por teoria tridimensional do Direito? Fundamente.

4ª) Mencione três dos principais ramos do Direito e defina-os sinteticamente.

5ª) Como se dá a hierarquia das normas jurídicas? Explique e fundamente.

6ª) O que se entende por antinomia? Quais os tipos de antinomia? Fundamente.

7ª) Quais os métodos de solução de conflitos? Fudamente.

2. NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

Bibliografia básica

BULOS, Uadi Lammêgo. **Direito Constitucional ao alcance de todos.** São Paulo: Editora Saraiva, 2011.
LENZA, Pedro. **Direito Constitucional Esquematizado.** São Paulo: Editora Saraiva, 2011.
NOVELINO, Marcelo. **Direito Constitucional**. São Paulo: Editora Método, 2011.

Bibliografia complementar

SILVA, José Afonso da. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. São Paulo: Editora Malheiros, 2011.

Legislação indicada

Constituição da República Federativa do Brasil.

2.1. Direito Constitucional

O Direito Constitucional, segundo José Afonso da Silva (2011), afigura-se como um **Direito Público Fundamental** por referir-se diretamente à **organização e funcionamento do Estado**, à **articulação de seus elementos primários** e ao **estabelecimento das bases da estrutura política** (grifos nossos).

Trata-se, assim, do "**conjunto de normas supremas**, encarregadas de **organizar a estrutura do Estado** e **delimitar as relações de poder"** (BULOS, 2011, p. 80).

O objeto de estudo do Direito Constitucional é a Constituição, que consiste na lei suprema do Estado brasileiro e **fundamento de validade de todas as demais normas jurídicas**.

Portanto, para que as demais normas jurídicas sejam válidas, é imprescindível que estejam **em conformidade com as normas constitucionais**.

Ressalte-se que o grau de importância do Direito Constitucional é enorme, vez que **todos os demais ramos do Direito encontram-se albergados nas diretrizes do Direito Constitucional** e devem criar seus institutos em consonância com as disposições da Constituição da República Federativa do Brasil.

O Direito Constitucional está alocado com ramo do Direito Público. Na verdade, trata-se do **Direito Público Fundamental ou Direito do Estado por excelência**.

No entanto, apesar da clássica dicotomia entre Direito Público e Privado, que remonta à época do Código de Napoleão (1804), **deve-se asseverar que, modernamente, vem sendo dito que o Direito é uno e indivisível**, devendo ser estudado como um grande sistema. Essa repartição entre público e privado deve ser encarada como uma mera conveniência acadêmica.

Além disso, o Direito Privado tem sofrido um processo de constitucionalização, sobretudo em razão da influência dos direitos fundamentais nas relações patrimoniais (tópico analisado com mais detalhe adiante).

2.2. Constituição: conceito e classificação;

2.2.1. Conceito e sentidos da Constituição

Segundo BULOS (2011), "Constituição é o organismo vivo delimitador da organização estrutural do Estado, da forma de governo, da garantia das liberdades públicas, do modo de aquisição e exercício do poder".

É uma **norma fundante que tem por objeto nuclear os direitos fundamentais**, a **estruturação do Estado** e a **organização dos poderes**, consideradas matérias tipicamente constitucionais.

A Constituição tem uma pluralidade de acepções ou sentidos, quais sejam: sentido sociológico, sentido jurídico e sentido político. Eis a análise detalhada de cada um.

Sentido sociológico – Idealizado por Ferdinand Lassalle, a concepção sociológica entende que a Constituição deve corresponder à **soma dos fatores reais de poder.** Caso não corresponda, ela não passaria de um "pedaço de papel". Uma Constituição, para ser duradoura e boa, deveria equivale a **Constituição real** – soma dos fatores reais de poder.

Sentido político – Defendido por Carl Schmitt, a concepção política entende que a Constituição é o conjunto de normas que dizem respeito a uma **decisão política fundamental**. São, portanto, normas que tratam de direitos individuais, organização do Estado, organização dos Poderes.

Ao revés, Lei Constitucional seria **toda norma que não envolvesse uma decisão política fundamental**, mas a simples regulamentação dos assuntos remanescentes, que ficaram fora da Constituição de um Estado (nesse sentido, Estado não está sendo utilizado com unidade da Federação, mas Estado-Nação, a exemplo do Brasil, dos EUA, da Alemanha, etc).

Diante disso, pode-se dizer que, segundo Schmitt, tudo aquilo que não for correlato a direitos individuais, organização do Estado e dos Poderes é lei constitucional, e não Constituição.

Sentido Jurídico – Concebido por Hans Kelsen, o sentido jurídico pode ser dividido em: a) **lógico-jurídico** – Constituição entendida como o fundamento lógico de todo o ordenamento jurídico; b) **jurídico-positivo** – Constituição encarada como uma norma positiva suprema.

Kelsen também dividiu a Constituição em **formal e material.**

Constituição formal é o procedimento solene, que só pode ser alterado mediante a observância de prescrições especiais, que visam dificultar o processo reformador. Constituição material, por sua vez, é a fonte regulatória das normas jurídicas em geral. Para BULOS (2011, p. 95), os legisladores, "ao criar atos normativos, devem observar, primeiro, o conteúdo da Constituição, de modo a evitar contradições entre a substância das normas constitucionais e o assunto que pretendem regulamentar.

2.2.2. Classificação das Constituições

2.2.2.1. Classificação quanto à **FORMA**

a) **Escrita** – As normas vêm prescritas e codificadas em um documento solene. Exemplo: Constituição Brasileira.

É difícil aparecer, no Brasil, um **costume constitucional (norma constitucional não escrita)**. Nossa Constituição é muito prolixa e trata de vários assuntos. No entanto, existe um costume que geralmente é mencionado. Trata-se do chamado **voto de liderança**. É o **único costume constitucional brasileiro do qual se tem notícia**.

Voto de liderança consiste, basicamente, no seguinte: As votações no Congresso Nacional são, em regra, **nominais** (os Deputados e Senadores devem votar **sim, não ou se abster**). Todavia, existem determinadas matérias, sobre as quais há um consenso no Parlamento, que podem ser submetidas à votação apenas das lideranças partidárias, com o objetivo de dar mais celeridade ao processo legislativo.

b) **Não-escrita ou Costumeira ou Consuetudinária** – As normas não vêm grafadas de modo único, sistemático, codificado e exaustivo em um procedimento formal e solene. Exemplo: Constituição Inglesa.

2.2.2.2. Classificação quanto à **SISTEMÁTICA** – É critério exclusivo das constituições escritas.

a) **Codificada** – é aquela Constituição que tem a forma de um código, que se caracteriza pela sistematização (organiza-se em títulos, subtítulos, seções, subseções, artigos, incisos, alíneas). **A Constituição de 1988 é organizada sistematicamente**.

b) **Não-codificada** – Constituição escrita, mas não codificada. Existem várias leis esparsas tratando de matéria constitucional. Aqui, encontramos **leis de emenda constitucional**, situadas em diplomas extravagantes, isto é, fora da Constituição. EX: Carta da França de 1975.

2.2.2.3. Classificação quanto à **ORIGEM**

a) **Democráticas ou populares ou votadas ou promulgadas** – a Constituição democrática deve ser elaborada por representantes do povo, **eleitos para o fim específico de elaborar a Constituição**. EX: Constituição Brasileira.

b) **Outorgadas ou Impostas** – O governante faz a Constituição e a impõe.

As Constituições outorgadas derivam de uma determinação do governante, seja ele rei, imperador, ditador, presidente, ou qualquer outra personalidade que titularize o Poder Constituinte Originário (vida explicações mais detalhadas sobre Poder Constituinte *infra*). Nestas Constituições, inexistem qualquer participação popular.

c) **Cesarista** – Trata-se de uma Constituição outorgada que é submetida a um plebiscito ou a um referendo.

Plebiscito e referendo são consultas populares. O primeiro é consulta prévia, enquanto o segundo é posterior a ratificação de uma medida já tomada.

ATENÇÃO: A constituição cesarista não se torna democrática por ser submetida a um plebiscito ou referendo.

d) **Pactuada** – É aquela surgida de um pacto entre o rei e a assembléia. Canotilho menciona como exemplo, a Constituição espanhola de 1830. Não é uma classificação tão comum, mas já caiu em prova do MP.

2.2.2.4. Classificação quanto à **FORMA DE ELABORAÇÃO**

a) **Dogmática** – Constituição feita a partir da consagração de dogmas e princípios dominantes em um determinado momento histórico. Surge de uma só vez. É o caso da Constituição de 1988.

b) **Histórica** – Não surge de uma só vez, mas de um lento processo que se prolonga através do tempo. É o caso das constituições não-escritas, baseadas nos costumes, a exemplo da Constituição Inglesa.

2.2.2.5. Classificação quanto à **PLASTICIDADE ou ESTABILIDADE**

a) **Rígidas** – Constituição que demanda, para sua alteração, um processo legislativo de alteração mais dificultoso, mais solene que o processo legislativo ordinário.

Para aprovação, a lei ordinária exige maioria relativa dos votos dos parlamentares e a lei complementar exige maioria absoluta.

Uma emenda constitucional (responsável por alterar a Constituição Federal), por sua vez, exige **3/5 dos votos dos membros do Congresso Nacional, mediante aprovação em dois turnos**, sob pena de inconstitucionalidade formal da emenda em caso de desrespeito do "quorum".

Ressalte-se que no nosso ordenamento constitucional existem **cláusulas pétreas**, **institutos que não podem ser alterados por emenda constitucional**. No entanto, a presença destas, como se viu, não é suficiente para determinar a rigidez de uma Constituição (o que determina é o processo de alteração).

É tanto que Alexandre de Moraes (2011) classifica as constituições rígidas com cláusulas pétreas **como superrígidas**.

b) **Semirrígidas** ou **semiflexíveis** – Contêm uma parte rígida (que só pode ser alterada por quorum diferenciado) e outra parte flexível (capaz de ser alterada pelo processo legislativo ordinário).

c) **Flexíveis** – Nestas, toda a Constituição pode ser alterada pelo processo legislativo ordinário. O parlamento desempenha o papel de assembléia constituinte permanente, modificando a Constituição da mesma forma que modifica as leis. Não existe hierarquia entre a Constituição e a lei. EX: Constituição Inglesa.

2.2.2.6. Classificação quanto à **EXTENSÃO**

a) **Concisa** ou **Sintética** ou **Sucinta** ou **Sumária ou Clássica** (constituição material) – as constituições tradicionalmente concisas vieram do Constitucionalismo liberal ou clássico (Constituição norte-americana e a francesa). **Concisa é aquela que trata só da matéria constitucional**.

b) **Prolixa** ou **Analítica** ou **Regulamentar** (constituição formal) – Trata de matérias constitucionais e não constitucionais.

Mas o que se ganha quando se coloca na Constituição matérias não constitucionais? **Confere-se a ela maior estabilidade**.

Eis o motivo pelo qual as Constituições ficarem cada vez maiores: conferir maior estabilidade a certos assuntos.

EX: Constituição Brasileira. Além das questões tipicamente constitucionais, trata de matérias tributárias, administrativas, financeiras, processuais, dentre inúmeros outros assuntos.

2.2.2.7. Classificação quanto à **FUNÇÃO ou ESTRUTURA**

a) Garantia – A Constituição-garantia tem como função **garantir direitos e liberdades**. Surgiram com as revoluções liberais, consagrando-se como o marco do constitucionalismo clássico e importantes instrumentos para limitar o poder arbitrário do Estado.

b) Dirigente – A Constituição dirigente, além de garantir os direitos individuais, também estabelece diretrizes, objetivos e programas de ação a serem implementados. Surgiram como evolução dos direitos fundamentais de segunda geração (direitos sociais) e do Estado Intervencionista, que veio se opor ao Estado Liberal.

O que caracteriza uma Constituição dirigente é o fato de ela conter **normas programáticas**. Por isso, são chamadas também de Constituições programáticas.

Classificação da CRFB/88 = escrita, codificada, democrática, dogmática, rígida (ou superrígida), prolixa, formal, dirigente, eclética e também chamada por alguns de compromissória (vários

compromissos subjacentes ao pacto fundador).

2.3 – Poder Constituinte

2.3.1. Poder constituinte originário

Poder constituinte originário é aquele que instaura uma nova ordem jurídica, **rompendo por completo a ordem jurídica precedente**.

"O objetivo fundamental do poder constituinte é criar um novo Estado, diverso do que vigorava em decorrência da manifestação do Poder Constituinte precedente" (LENZA, 2011, p. 154).

Trata-se de Poder **de fato ou político**, vez que retira sua força **da energia social**, e não do Direito.

2.3.1.1. FENÔMENO CONSTITUINTE:

É a **forma de expressão do poder constituinte originário**. Segundo a doutrina, existem duas formas de manifestação do poder constituinte, quais sejam:

a) Revolução: É toda ruptura com o ordenamento jurídico anterior. Dá-se com o nascimento de uma nova constituição.

Existem duas espécies de revolução:

Golpe de Estado: alguém que detém o poder constituído passa a exercer o poder constituinte (geralmente o Chefe de Estado). EX: Golpe militar de 1964.

Insurreição: é a revolução propriamente dita – um grupo externo aos poderes constituídos passar a exercer o poder constituinte. EX: revolução popular.

b) Transição Constitucional: O melhor exemplo desse fenômeno ocorreu recentemente em nossa história – a Constituição brasileira de 67/69 passou a prever, através de emenda, a realização de uma eleição responsável pela escolha da Assembléia Nacional Constituinte, que se encarregaria da elaboração da Constituição Federal de 1988.

2.3.1.2. ESPÉCIES DE PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO:

a) Quanto ao momento de surgimento:

Poder Constituinte Originário Histórico: Responsável por elaborar a primeira constituição dentro de um Estado. EX: Brasil – Constituição Imperial de 1824.

Poder Constituinte Originário Revolucionário: Incumbido de preparar a nova Constituição em um Estado. EX: Brasil – Constituição Republicana de 1891.

Poder Constituinte Originário Transicional: Surge através de regras específicas em transição constitucional.

b) Quanto à realização:

Material: Será responsável pelo conteúdo a ser consagrado na Constituição.

Formal: Realiza a consagração do conteúdo escolhido pelo Poder Constituinte Originário Material através das normas jurídicas.

Assim, em uma constituição democrática, o povo escolheria o conteúdo (Poder Constituinte originário material), que seria formalizado pela Assembléia Nacional Constituinte (Poder Constituinte originário formal).

2.3.1.3. CARACTERÍSTICAS DO PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO

a) Inicial – não existe nenhum outro Poder antes ou acima dele.

b) Autônomo – tem autonomia para estabelecer qual idéia de Direito irá prevalecer naquele determinado Estado.

c) Incondicionado – não se submete a qualquer condição formal ou material.

d) Soberano.

e) Independente.

2.3.2. Poder Constituinte Decorrente

O Poder Constituinte decorrente é aquele que irá elaborar as Constituições dos Estados-membros (unidades da Federação).

O Estado-membro tem capacidade de auto-organização e autolegislação, mas a Constituição Estadual encontra limites na CF, segundo o **princípio da simetria** – algumas normas constitucionais devem ser obrigatoriamente reproduzidas na seara estadual, a exemplo das regras atinentes ao processo legislativo.

2.3.2.1. LIMITAÇÕES AO PODER CONSTITUINTE DECORRENTE

O Poder Constituinte Decorrente **é limitado pelos seguintes princípios constitucionais**:

a) Princípios constitucionais sensíveis: art. 34, VII – assim denominados por Pontes de Miranda.

> Art. 34, VII, CF: A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:
>
> VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:
>
> **a) forma republicana**, sistema representativo e regime democrático;

> **b) direitos da pessoa humana;**
>
> **c) autonomia municipal;**
>
> **d) prestação de contas da administração pública**, direta e indireta;
>
> **e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais**, compreendida a proveniente de transferências, **na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde**.

São princípios que tratam da **essência da organização da federação brasileira**. Se um princípio sensível for violado, o Presidente pode – após representação do PGR via ADI interposta no Supremo Tribunal Federal – decretar a Intervenção Federal no Estado-membro.

b) Princípios extensíveis: previstos para a União e se estendem aos estados membros, de forma expressa ou de forma explícita.

De forma expressa: art. 28, CF.

> Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de quatro anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em primeiro de janeiro do ano subseqüente, **observado, quanto ao mais, o disposto no art. 77**.

De forma implícita: Princípios gerais do processo legislativo – o art. 61, §1º, da CF, fala das matérias de iniciativa exclusiva do Presidente da República, que, no âmbito estadual, devem ser conferidas exclusivamente ao governador;

c) Princípios estabelecidos: esses princípios serão estabelecidos aos estados de forma expressa ou implícita.

De forma expressa: EX: O artigo 19, da CF, estabelece uma série de vedações aos entes políticos, a saber:

> Artigo 19. É vedado à União, **aos Estados**, ao Distrito Federal e aos Municípios:
> I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;
> II - recusar fé aos documentos públicos;
> III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

De forma implícita: ex. art. 22, CF. Trata das matérias afetas a União para legislar. Implicitamente, está-se vedando ao Estado a possibilidade de legislar sobre tais matérias.

2.3.3. Poder Constituinte Derivado, Instituído ou Reformador

É aquele que vai **alterar a Constituição**. Tal poder encontra limites que estão previstos no art. 60 da CF.

> Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
> I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
> II - do Presidente da República;
> III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
> § 1º - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
> § 2º - A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.
> § 3º - A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.
> § 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
> I - a forma federativa de Estado;
> II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
> III - a separação dos Poderes;
> IV - os direitos e garantias individuais.
> § 5º - A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

2.3.3.1. ESPÉCIES DE LIMITES:

a) Temporais: são limites que irão impedir a alteração da Constituição durante determinado período de tempo. Essa limitação é normalmente prevista na primeira Constituição de Estado. Ex. Constituição de 1824 não poderia ser modificada durante o período inicial de quatro anos.

b) Circunstanciais: impedem a modificação da constituição em determinadas circunstâncias, quais sejam: intervenção Federal, estado de Defesa e estado de Sítio.

c) Formais, processuais ou procedimentais: estão relacionados ao processo de modificação da constituição. Dividem-se em subjetivos e objetivos:

Subjetivos: são limites relacionadas ao sujeito competente para propor emenda constitucionais. O rol de legitimados está previsto no artigo 60 da Constituição Federal.

Objetivos: Relacionam-se ao procedimento de elaboração de emenda constitucional após a iniciativa.

A emenda **deverá respeitar "quorum" de aprovação da 3/5 dos membros do Congresso Nacional, mediante votação em 2 turnos** (art. 60, §2º). A **promulgação deverá ser feita pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal** (as duas em conjunto), segundo previsão do art. 60, §3º.

A última limitação formal objetiva está prevista no art. 60, §5º, segundo o qual se a matéria for rejeitada (ou havida por prejudicada) numa sessão legislativa, não poderá ser reapresentada novamente na mesma sessão legislativa.

OBS: A Sessão legislativa (art. 57) não pode ser confundida com a legislatura (art. 44, parágrafo único). Esta última perdura pelos quatro anos do mandato, englobando quatro sessões legislativas – período anual, que não coincide com o calendário civil (vai do dia **02/02 a 17/07** e do **dia 01/08 a 22/12**).

d) Limitações Materiais ou Substanciais: se refere a determinadas matérias, que não podem ser objeto de emenda constitucional. São as chamadas cláusulas pétreas e estão previstas no artigo 60, §4º, da Constituição Federal.

2.4. Princípios fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil.

No caput do artigo 1º, da Constituição Federal, estão consagrados os **princípios matérias materiais estruturantes**, que constituem diretrizes fundamentais para toda a ordem constitucional, quais sejam: princípio republicano, princípio federativo e Estado Democrático de Direito.

Além destes, encontramos nos incisos do mesmo artigo os fundamentos ou **valores estruturantes do Estado Brasileiro** – soberania, cidadania, valores sociais do trabalho, pluralismo político e **dignidade da pessoa humana**. Este último, inclusive, é considerado o valor supremo de nosso ordenamento jurídico.

> Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
>
> I - a soberania;
>
> II - a cidadania;
>
> III - a dignidade da pessoa humana;
>
> IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
>
> V - o pluralismo político.
>
> Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

a) Princípio Republicano este princípio traz consigo uma tripla exigência: responsabilidade, eletividade e temporariedade dos cargos públicos políticos.

b) Princípio Federativo (ver tópico organização do Estado).

c) Estado Democrático de Direito se revela um tipo de Estado que busca uma profunda transformação do modo de produção capitalista, com o objetivo de construir uma sociedade na qual possam ser implantados nomes reais de igualdade e liberdade.

d) Soberania pode ser definida como um poder político supremo e independente. Supremo, por não estar limitado por nenhum outro na ordem interna; independente, por não ter de acatar, na ordem internacional , regras que não sejam voluntariamente aceitas e por estar em igualdade com os poderes supremos dos outros povos.

e) Cidadania ao lado dos direito políticos, compreendem-se em seu conteúdo os direitos e garantias fundamentais referentes à atuação do indivíduo em sua condição de cidadão.

f) Valores sociais do trabalho impede a concessão de privilégios econômicos condenáveis, por ser o trabalho imprescindível à promoção da dignidade da pessoa humana. A partir do momento que contribui para o progresso da sociedade à qual pertence, o indivíduo se sente útil e respeitado.

g) Pluralismo político decorre do princípio democrático, que impõe a opção por uma sociedade plural na qual a diversidade e as liberdades devem ser amplamente respeitadas.

h) Dignidade da pessoa humana impõe-se o reconhecimento de que a pessoa não é simplesmente um reflexo da ordem jurídica, mas, ao contrário, deve constituir o seu objetivo supremo, sendo que na relação entre o indivíduo e o Estado deve haver sempre uma *presunção a favor do ser humano e de sua personalidade.*

2.5. Direitos e garantias fundamentais

2.5.1. Diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais

A expressão Direitos Humanos é empregada para designar os direitos fundamentais no seu plano internacional. Já os direitos humanos positivados por um determinado Estado receberam a designação de direitos fundamentais.

Direitos fundamentais, conforme José Afonso da Silva (2011), consistem nas “prerrogativas e instituições que o direito positivo concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas”.

2.5.2. Características

Os direitos fundamentais possuem as seguintes características:

Historicidade: os direitos fundamentais são históricos, ou seja, com o passar dos tempos, novos grupos de direito poderão ser considerados fundamentais, ao passo que outros poderão deixar de sê-lo. Isto porque o conceito do que é essencial a uma vida digna pode variar com o tempo.

Inalienabilidade: os direitos fundamentais são inalienáveis. Não podendo ser objeto de negócios jurídicos.

Imprescritibilidade: os direitos fundamentais são imprescritíveis, não se perdendo pelo não-uso.

Irrenunciabilidade: o titular de tais direitos não pode renunciá-los;

2.5.3. Dimensões

Os direitos fundamentais possuem duas perspectivas ou dimensões: **a subjetiva e a objetiva**.

A **dimensão subjetiva** – concepção mais clássica – aborda os direitos fundamentais como direitos subjetivos, impedindo a atuação estatal tendente a lesá-los.

Esta dimensão aborda os direitos fundamentais como freios ao poder estatal, que, em diversos casos, tende a lesar os direitos e garantias dos indivíduos.

Na **dimensão objetiva**, os direitos fundamentais são encarados como os valores fundamentais de uma sociedade. Trata-se de uma dimensão mais moderna.

Deve-se salientar, contudo, que uma dimensão não exclui a outra, pois se complementam.

2.5.4. Eficácia dos direitos fundamentais

A eficácia dos direitos fundamentais divide-se em horizontal e vertical.

Eficácia vertical – caracteriza-se pela sua aplicação nas relações entre o Estado e os indivíduos da sociedade, devendo o Estado respeitar os direitos dos indivíduos.

Eficácia horizontal – consiste na aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre os particulares, de modo que os indivíduos devem respeitar os direitos fundamentais dos outros.

2.5.5. Classificação

a) Direitos formalmente fundamentais e materialmente fundamentais

Diretos materialmente fundamentais são aqueles essenciais a uma vida humana digna, independentemente de estarem positivados ou não em uma Constituição.

Direitos formalmente fundamentais são aqueles que adquirem essa característica porque se encontram previstos como tais em uma Constituição.

b) Classificação de acordo com as gerações de direitos fundamentais

Direitos de primeira geração – são chamados de “direitos de liberdade” ou “liberdades públicas”.

Surgiram como uma forma de limitação do poder das monarquias absolutistas, que estavam em plena decadência, ante o surgimento das primeiras constituições escritas, fundadas no movimento constitucionalista no fim do século XVIII (Revolução Francesa).

Nesta época, a função dos direitos fundamentais era defender os cidadãos das ingerências indevidas do Estado. Era o Estado Liberal, também chamado de Estado Mínimo, ou Estado da Abstenção.

Falava-se que as relações sociais e econômicas dos indivíduos eram “controladas pela mão invisível do Estado” (expressão de Adam Smith).

Direitos de segunda geração – Com a Revolução Industrial, surgiu um grande número de mão de obra para pouco emprego, acarretando uma degradação dos trabalhadores urbanos, surgindo um novo conceito de direitos essenciais a uma vida digna: os direitos sociais, a segunda geração dos direitos fundamentais.

Exige-se do Estado uma prestação (um fazer), aparecendo uma nova função dos direitos fundamentais: a função de prestação do Estado (prestação material e legislativa).

Este Estado intervencionista recebeu a denominação de Estado do Bem-estar Social (“walfare state”).

Direitos de terceira geração – No século XX, após as guerras mundiais, passou-se a entender que, para uma vida humana digna, necessitava-se de direitos difusos e coletivos, tais como o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, a proteção aos consumidores, dentre outros.

A dignidade da pessoa humana passou a ter um aspecto difuso e coletivo para se atender aos novos anseios sociais.

OBS: Parcela da doutrina já admite a existência de uma 4ª geração de direitos fundamentais. Para Paulo Bonavides, seriam direitos de **quarta geração** os relacionados à democracia.

2.5.7. O direito fundamental à vida

O direito à vida consiste em pré-requisito básico para o exercício de todos os outros direitos fundamentais. Sem direito à vida não há como se falar dos outros direitos. O direito à vida possui alguns desdobramentos ou dimensões: **direito à existência, direito à vida digna e direito à integridade física moral**.

Como todo direito fundamental, o direito à vida também não é absoluto, podendo ser relativizado pela legítima defesa, por exemplo.

A Constituição Federal prevê uma única possibilidade de pena de morte: no caso de guerra declarada, e, ainda assim, neste caso, para se decretar a morte de alguém, deve-se sempre se valer de critérios de razoabilidade.

A dignidade da pessoa humana seria outra dimensão do direito à vida (direito a uma vida digna). Não basta existir, a existência deve ser digna.

Outra dimensão do direito à vida consiste no direito à integridade física e moral. A nossa Constituição Federal, tutelando a integridade física, dispõe que ninguém será submetido à prática de tortura nem a tratamento desumano ou degradante, vedando também as penas cruéis.

2.6. Organização do Estado

Inicialmente, deve-se salientar que a organização e estrutura do Estado pode ser realizada sob três aspectos, quais sejam: forma de Estado, forma de governo e sistema de governo.

2.6.1. FORMAS DE ESTADO

Estado Unitário: Apenas um centro de poder incide sobre todo o território. O governo central (poder unitário), ainda que exista descentralização político-administrativa (a delegação é feita por aquele que detém o poder e não pela Constituição).

Estado Federal: Há mais de um centro de poder, incidindo sobre a mesma população, no mesmo território. Ex. No território de um município, há incidência do poder federal, estadual e municipal.

No Brasil, adota-se o estado federal desde a proclamação da República (15/11/1889). A primeira Constituição Brasileira que consagrou a forma Federativa de Estado foi a de 1891. Até a proclamação da República, o Brasil era considerado um Estado unitário (Brasil império e Brasil Colônia).

OBS: A palavra federação vem de *foedus, fuederis* que significa pacto, aliança, união; e originariamente não se divide em municípios, mas apenas em estados membros. A divisão entre municípios é uma peculiaridade do Brasil.

2.6.2. FORMAS DE GOVERNO:

Monarquia: é o poder concentrado nas mãos de apenas um indivíduo.

Aristocracia: concentração de Poder nas mãos de alguns indivíduos.

República: é o governo do povo. É a forma de governo adotada no Brasil.

2.6.3. SISTEMAS DE GOVERNO

Presidencialismo: as funções de Chefe de Estado (representação) e Chefe de Governo

(Diretrizes do Governo) concentram-se em uma mesma pessoa.

Parlamentarismo: há separação entre as funções de Chefe de Estado e Chefe de Governo. A depender da forma de Governo, o Chefe de Estado será o Presidente da República (EX: Alemanha e Itália) ou o Monarca (EX: Inglaterra e Espanha).

O Chefe de Estado é uma figura simbólica. O Chefe de Governo (primeiro Ministro) que comanda as políticas internas.

2.6.4. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DE UMA FEDERAÇÃO

a) Descentralização político-administrativa prevista na Constituição

Para um Estado ser considerado um estado federal, não basta mera descentralização de poder. É possível haver descentralização de poder sem que haja federação. Nesse caso, o ente central faz uma delegação que pode ser retirada a qualquer momento.

É a constituição que tem q descentralizar político-administrativamente o Estado.

Descentralização política é a **competência de elaboração de leis**. Descentralização administrativa é a competência para **executar os comandos contidos nas leis**.

b) Participação das vontades parciais na formação da vontade geral

No caso do Brasil, os domínios parcelares participam da vontade geral através do Senado Federal, vez que este é **composto de representantes dos Estados-membros**.

É por isso que a representação no Senado é igual para todos os Estados-membros, independentemente da população do referido estado.

c) Autonomia dos Estados Membros

Esta autonomia dos Estados membros é uma autonomia organizatória. Os Estados-membros em uma federação têm uma capacidade conferida pela Constituição de se auto-organizarem, o que se materializa por meio das Constituições estaduais.

2.6.5. TIPOS DE FEDERALISMO OU FEDERAÇÃO

Quanto ao surgimento: refere-se à formação da federação. Analisa-se como foi formado o estado federativo.

a) Federação por agregação: surge a partir da União de Estados soberanos, que cedem uma parcela de soberania para a formação de um ente único. EX: Estados Unidos da América.

b) Federação por segregação: surge a partir da divisão de um Estado Unitário em vários domínios parcelares autônomos. Tem-se o movimento inverso do federalismo por agregação. O poder central é dividido com os domínios parcelares. Ex. Brasil.

Quanto a repartição de competências:

a) Federalismo Dualista: Não há submissão de um ente ao outro. A competência é distribuída de maneira equânime entre os entes. **Esse é o federalismo clássico norte-americano**.

b) Federalismo por Integração: há uma relação de subordinação entre a União e os estados membros. Opõem-se frontalmente ao federalismo dualista.

c) Federalismo Cooperativo: é o federalismo adotado no Brasil e nos EUA após a quebra da bolsa em 1929. Nesse federalismo, há uma **tentativa de cooperação entre os entes para que as competências possam funcionar bem**.

Quanto à concentração do poder

a) Federalismo centrífugo: quando se tem uma **reação ao poder central**, fala-se em federalismo centrífugo.

b) Federalismo centrípeto: o poder se concentra na União. Esta possui muito mais competências que o Estado-membro. **O poder está perto do centro**. EX: Brasil.

No Brasil, há um federalismo centrípeto, mas a federação brasileira surgiu através de um movimento centrífugo.

2.6.6. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS

A Constituição Federal, ao estabelecer a repartição de competências, utiliza-se do **Princípio da Predominância do Interesse.** Assuntos de interesse predominantemente geral são atribuídos à **União**. Se o assunto for de interesse predominantemente local, a competência será do **Município**, e as demais competências (interesse regional) serão atribuídas ao **Estado-membro**.

A partir desse princípio informador, a Constituição traz quatro critérios para a distribuição de competências:

a) Campos específicos de Competência Legislativa e Administrativa

A Constituição estabelece **poderes enumerados para a União**. O artigo 21 traz as competências administrativas e o artigo 22 traz as competências legislativas.

OBS: quando a Constituição estabelece diretamente uma competência administrativa, indiretamente está atribuindo, também, uma competência legislativa, e vice-versa.

Também são estabelecidos poderes enumerados aos Municípios, conforme o artigo 30 da CF – não há separação entre competências legislativas e administrativas, diante do pequeno rol de competências.

Já no que tange aos estados-membros a Constituição estabeleceu poderes remanescentes ou residuais, segundo dispõe o art. 25, §1º da CF.

No que tange ao Distrito Federal, cujas competências estão previstas no art. 32, §1º, temos que, **diante da impossibilidade de divisão em municípios**, o DF irá acumular as competências dos estados e dos municípios, no âmbito administrativo e legislativo.

b) Possibilidade de delegação

As Constituições normalmente estabelecem possibilidade de delegação de algumas competências, devendo ser observado que:

b.1) **A União somente pode delegar suas competências legislativas privativas aos Estados-membros e ao Distrito Federal (que tem competência estadual)**, mas não aos municípios;

b.2) Esta delegação só poderá ser viabilizada **mediante a edição de lei complementar**.

É o que dispõe o art. 22, parágrafo único da CF: “Lei complementar poderá autorizar os Estados a

legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo".

c) Competências comuns:

Basicamente existem duas diferenças entre competências comuns e competências concorrentes:

c.1) **As competências comuns são competências administrativas, pelo menos diretamente**.

c.2) As competências comuns são exercidas por todos os entes da federação, inclusive os municípios.

d) Competências concorrentes:

As competências concorrentes se referem às competências legislativas e cabem à União, aos Estados e ao Distrito Federal. Não há inclusão dos Municípios, o que pode ser percebido através da leitura do art. 24 da CF.

OBS1: O Município, malgrado não tenha competência concorrente, pode legislar sobre as matérias do artigo 24, vez que, segundo o artigo 30 da Constituição Federal, **compete aos municípios suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, ou seja, nos assuntos de interesse predominantemente local.**

OBS2: A Constituição estabelece que, no âmbito da legislação concorrente, **a União limita-se ao estabelecimento de normas gerais,** enquanto os Estados o e Distrito Federal regulamentam as matérias de acordo com suas peculiaridades regionais.

Caso haja omissão da União na edição de normas gerais, cabe ao estado membro **legislar plenamente** acerca da matéria, ou seja, legisla acerca de normas gerais e de normas específicas para o Estado-membro. Sobrevindo lei federal sobre normas gerais, esta suspenderá a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrária.

Sendo assim, na competência concorrente os Estados exercem competências suplementar, que pode ser divida em: **a) Competência suplementar complementar**: Estado-membro apenas complementa as normas gerais editadas pela União, adequando-as às suas peculiaridades; **b) Competência suplementar supletiva:** Não há lei geral federal acerca da matéria e o Estado exerce competência plena.

2.7. Questões

1ª) Discorra sobre o objeto de estudo do Direito Constitucional.

2ª) A Constituição Federal de 1988 pode ser classificada como:

a) promulgada, escrita, analítica, formal e rígida.

b) promulgada, instrumental, sintética, material, histórica e rígida.

c) outorgada, escrita, analítica, formal e rígida.

d) pactuada, instrumental, formal, analítica e semirrígida.

e) pactuada, consuetudinária, prolixa, formal e rígida.

3ª) Diz-se que a Constituição brasileira de 1988 é *rígida* porque:

a) não admite a ocorrência do fenômeno da mutação constitucional.

b) classifica como inafiançáveis os crimes de racismo e tortura, entre outros

c) prevê, para sua reforma, a adoção de procedimento mais complexo, em tese, do que o adotado para a modificação das leis.

d) estabelece penalidades severas para os crimes de responsabilidade.

e) foi promulgada por Assembléia Nacional Constituinte convocada na forma de Emenda à Constituição anterior.

4ª) Assinale certo ou errado, conforme o enunciado a seguir:

A concepção política de Constituição, elaborada por Carl Schmitt, compreende-a como o conjunto de normas que dizem respeito a uma decisão política fundamental, ou seja, a vontade manifestada pelo titular do poder constituinte.

5ª) Assinale certo ou errado, conforme o enunciado a seguir:

Denomina-se constituição outorgada a elaborada e estabelecida com a participação do povo, normalmente por meio de Assembleia Nacional Constituinte.

6ª) Em matéria de Poder Constituinte analise:

I. O poder que a Constituição da República Federativa do Brasil vigente atribui aos estados-membros para se auto organizarem, por meio da elaboração de suas próprias Constituições.

II. O poder que tem como característica, dentre outras, a de ser ilimitado, autônomo e incondicionado.

Esses poderes dizem respeito, respectivamente, às espécies de poder constituinte

a) decorrente e originário.

b) derivado e reformador.

c) reformador e revisor.

d) originário e revisor.

e) decorrente e derivado.

7ª) Cite e fundamente três princípios fundamentais da República Federativa do Brasil.

8ª) Disserte sobre as dimensões dos direitos fundamentais.

9ª) Assinale certo ou errado, conforme o enunciado a seguir:

No parlamentarismo as funções de Chefe de Estado (representação) e Chefe de Governo (Diretrizes do Governo) concentram-se em uma mesma pessoa.

10ª) Rediga uma breve texto sobre o princípio da predominância de interesses e as competências comuns e concorrentes.

GABARITO

2. a; 3. c; 4. CERTO; 5. CERTO; 6. a; 9. ERRADO;

3. DIREITO ADMINISTRATIVO

Bibliografia básica

ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. **Direito Administrativo Descomplicado.** São Paulo: Editora Método, 2011.

Bibliografia complementar

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2011.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo.** São Paulo: Editora Atlas, 2011.

MELLO, Celso Albuquerque Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo**. São Paulo: Editora Malheiros, 2011.

Legislação indicada

Legislação Administrativa da Editora Saraiva (ano 2011);

3.1. Conceito de Direito Administrativo;

São inúmeros os conceitos apresentados pela doutrina administrativista, "especialmente porque há autores que adotam critérios distintos para a demarcação do campo de atuação desse ramo" (ALEXANDRINO; PAULO, 2011, p. 3). Eis as diversas definições:

a) Para o Professor Celso Antônio Bandeira de Mello, o Direito Administrativo é o ramo do Direito público que disciplina a função administrativa e os órgãos que a exercem.

b) Hely Lopes Meirelles (conceito mais adotado) entende que Direito Administrativo é um **conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos**, **os agentes e as atividades atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado**.

c) Maria Sylvia Zanella di Pietro define o Direito Administrativo como o ramo do Direito Público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas quer integram a Administração Pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens que se utiliza para a consecução de seus fins, de natureza pública.

3.2. Administração pública;

3.2.1. Regime Jurídico da Administração Pública

O Direito Administrativo tem como base o **regime jurídico administrativo**, que consiste no **conjunto de regras e princípios que regem a Administração Pública**, guardando, entre si, uma coerência lógica.

É importante ressaltar que os princípios não podem ser aplicados de forma absoluta. **Devem ser avaliados em conjunto**. Essa idéia é denominada **ponderação de interesses:** todos os princípios têm a mesma força e importância, analisando-se, no caso concreto, qual princípio deve prevalecer após a ponderação de interesses.

Eis a análise dos princípios mais relevantes:

a) Supremacia do Interesse público: Junto com o princípio da indisponibilidade do interesse público formam o que Celso Antônio Bandeira de Mello denominou **"pedras de toque do Direito Administrativo".**

Interesse público é o somatório dos interesses da maioria, que, para ser legítimo, deve representar a vontade da maioria.

Divide-se em interesse público primário e secundário. O primeiro representa a **vontade social** – somatório das vontades individuais. Já o segundo representa a **vontade do Estado enquanto pessoa jurídica**. Em regra, **esses dois interesses devem estar em harmonia**, pois, em tese, os anseios do Estado devem se coadunar com os interesses do povo. **Havendo divergência entre eles, o que deve prevalecer é o interesse primário**.

Supremacia do Interesse público, portanto, **significa a superioridade do interesse público em face do individual**. Essa superioridade é pressuposto essencial para o convívio em sociedade. Exemplos de aplicação prática do princípio: Cláusulas exorbitantes em contratos administrativos; Desapropriação por interesse público.

b) Indisponibilidade do Interesse público: É forma de limitar a supremacia, já que a **Administração Pública não pode dispor do interesse público**. EX: o administrador que deixa de realizar concurso público está lesando o princípio da indisponibilidade do interesse público.

A função pública é obrigação. O administrador não pode dispor livremente do interesse público.

Princípios mínimos do Direito Administrativo (LIMPE) – art. 37, caput, Constituição Federal:

L – Legalidade
I – Impessoalidade
M – Moralidde
P – Publicidade
E – Eficiência

c) Princípio da Legalidade:

A Legalidade no Direito Público não se confunde com a legalidade no Direito Privado. No Direito Privado, o particular pode fazer tudo que não está vedado em lei (o que não está proibido é lícito). **No Direito Público, ao revés, o agente só pode fazer o que está na lei (subordinação à lei)**. Se o agente não agir conforme a lei, o ato será ilegal, passível de anulação.

O prazo que a Administração Publica tem para anular atos ilegais que trouxeram efeitos favoráveis para o administrado é de **5 anos**, salvo se tiver havido má fé, de acordo com o artigo 54 da Lei 9784/99 (Lei de Processo Administrativo Federal).

Questão importante: A legalidade pode ser relativizada pelo principio da segurança jurídica? Suponha-se que um ato foi praticado de forma ilegal. No entanto, a Administração só foi atentar para a ilegalidade 30 anos depois. Anula-se o ato ou o mantém em nome da **segurança jurídica**? Nesse exemplo, **se a retirada do ato trouxer mais prejuízos do que benefícios haverá uma relativização do principio da legalidade em nome do principio da segurança jurídica (ponderação de interesses)**. O ato deverá permanecer no ordenamento jurídico, mesmo de forma ilegal, havendo a estabilização dos seus efeitos. Este instituto é consagrado pelo Supremo Tribunal Federal.

d) Princípio da Impessoalidade

O administrador não pode buscar interesses próprios, nem de parentes, amigos. Ele precisa agir com ausência de subjetividade. A impessoalidade não permite tratamentos favoritistas.

Para Celso Antonio Bandeira de Mello, “a Administração Pública deve tratar os administrados sem discriminações benéficas ou detrimentosas, nem favoritismos nem perseguições são toleráveis, simpatias ou animosidades políticas, pessoas ou ideologias não podem interferir na atividade administrativa”.

e) Princípio da Moralidade

Reúne a idéia de honestidade. O administrador deve respeitar os princípios éticos, de boa-fé. Deve agir com correção de atitude, deve ser leal.

Mas esse conceito ainda é vago, aberto demais, o que dificulta sua aplicação.

O Poder Judiciário ainda tem dificuldades na aplicação desse princípio de forma isolada diante da abertura de seu conceito. Agir de forma imoral importa em crime de responsabilidade (Lei 8429/92).

f) Eficiência

Foi introduzido de forma expressa na Constituição Federal a partir da Emenda Constitucional 19/1998. Todavia, a Lei 8987/95, em seu art. 6º, já exigia a eficiência na administração ao conceituar serviço adequado.

Eficiência significa a ausência de desperdícios, agir com economia, produtividade, agilidade, celeridade, presteza. Para alcançar a eficiência, o constituinte pensou em alguns mecanismos/institutos, merecendo destaque:

Alteração da estabilidade do serviço público (art. 41, CF): Passou-se a exigir, além dos três anos de efetivo exercício, a aprovação em uma **avaliação de desempenho.** O servidor deve permanecer eficiente, pois será avaliado em avaliação periódica de desempenho e se não aprovado irá perder a estabilidade.

Gastos excessivos com folha de pagamento: o constituinte, alterando o art. 169 da CF, passou a estabelecer limites de despesa com pessoal, previstos em Lei Complementar (LC 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal).

Caso esse limite não esteja sendo respeitado pelos entes públicos, será preciso conter gastos e cortar o funcionalismo, seguindo-se a seguinte ordem de medidas:

1ª) Redução de cargo em comissão e função de confiança em 20%, pelo menos;

2ª) Exoneração de servidores não estáveis: quantos forem necessários para conter os gastos. A escolha recairá de acordo com a desnecessidade;

3ª) Exoneração de servidores estáveis.

OBS: O ato que será utilizado, no caso, será a exoneração e o cargo será extinto, somente podendo ser recriado cargo com as mesmas atribuições, após 04 anos (A finalidade foi evitar “vinganças” fruto de politicagem). Dentre essas hipóteses, o servidor estável é o único que tem direito a indenização.

ATENÇÃO FINAL: A eficiência não deve estar apenas nos meios nem só no resultado. Deve-se gastar o menor valor possível para obter o melhor resultado.

3.2.2. Noção de organização da Administração Pública

A Administração Pública Direta (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) não pode realizar, sozinha, todas as suas atribuições. Portanto, deve atribuir competências a **órgãos (desconcentração)** ou a **entidades (descntralização)**.

O **órgão** recebe a competência e **não tem personalidade**. A **entidade** recebe a competência e **tem personalidade**.

Os órgãos são disciplinados, em regra, pelo princípio da **subordinação hierárquica**. Isso não acontece nas entidades, que são **vinculadas, mas não subordinadas** a Ministérios.

Muito importante – Todas as entidades da Administração indireta (autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas) estão sujeitas a **supervisão ministerial**, que consiste em um poder do Ministro "conformar a atuação da entidade em relação aos padrões legais".

Isso significa que o Ministro não tem ascendência hierárquica sobre a autarquia, não manda na autarquia. Mas se a Autarquia pratica um ato ilegal, o Ministro pode realizar o controle deste ato da autarquia, anulando-o.

Ressalte-se que isso só é possível quando o ato for ilegal, nunca por razões de mérito.

ATENÇÃO: Lembrar que, na subordinação hierárquica, ao contrário da supervisão ministerial, o controle é de legalidade e de mérito.

3.3. Atos Administrativos;

3.3.1. Conceito

Ato administrativo é uma manifestação ou declaração da Administração Pública – nesta qualidade – ou de particulares – no exercício de prerrogativas públicas – que tenha por fim imediato a **produção de efeitos jurídicos determinados**, em conformidade como o interesse público e sob o regime predominantemente de Direito Público.

3.3.2. Atributos ou Características do Ato Administrativo

A doutrina clássica admite três atributos e a doutrina moderna inclui um quarto atributo.

a) Presunção de Legitimidade:

A presunção de legitimidade traz consigo a presunção de legalidade e de veracidade. O ato é presumidamente legítimo, obedecendo a normas morais; presumidamente legal, obedecendo a lei; e presumidamente verdadeiro, já que corresponde a realidade.

Trata-se de presunção relativa ("iuris tantum"), admitindo prova em contrário.

b) Autoexecutoriedade:

O **ato pode ser praticado sem autorização ou controle prévio do Poder Judiciário.**

Para a maioria da doutrina, a autoexecutoriedade **tem dois enfoques**:

b.1) Exigibilidade: poder de **decidir** sem a presença do Judiciário. **Esta característica todo ato possui.**

b.2) Executoriedade: é o poder de **exigir de forma direta**, sem auxílio do Poder Judiciário. É meio de coerção direto. **Nem todo ato administrativo possui essa característica. Somente estará presente se houver previsão legal ou se tratar de situação urgente.**

c) Imperatividade

O ato administrativo goza da obrigatoriedade, da coercibilidade e deve ser cumprido independentemente da concordância do particular. A doutrina majoritária diz que esse atributo também não é comum de todos os atos administrativos. A imperatividade é característica dos atos administrativos que constituem uma obrigação.

Atos enunciativos não constituem obrigação e, portanto, não gozam da imperatividade. Ex. um parecer, um atestado, uma certidão, não obrigam ninguém a nada.

d) Tipicidade

Cada ato administrativo tem aplicação específica, ou seja, é usado para uma situação determinada. EX: a anulação serve para anular atos cobertos de ilegalidade.

3.3.3. Formação, validade e eficácia do ato administrativo

a) Formação do ato administrativo

O ato administrativo deve seguir um **ciclo de formação**. Será **perfeito** caso cumpra referido ciclo.

b) Validade do Ato administrativo

Ato administrativo válido é aquele que **atende aos requisitos da lei**.

c) Eficácia do Ato Administrativo

Ato administrativo eficaz é aquele que **está pronto para produzir os feitos**. Tem capacidade para tanto.

O ideal é que o ato administrativo seja **perfeito, válido e eficaz.** No entanto, existem algumas circunstâncias em que isso pode não irá ocorrer, a saber:

Exemplo de ato perfeito, válido e **ineficaz**: contrato administrativo que não é publicado conforme determina o art. 61, parágrafo único da Lei 8.666. A publicação do contrato é condição de eficácia do ato administrativo.

Exemplo de ato perfeito, **inválido** e eficaz: concurso que é homologado, os servidores tomam posse e posteriormente há declaração de invalidade. Houve perfeição e produção de efeitos, malgrado ato seja inválido.

O ato inválido produz efeitos até a sua declaração de invalidade (anulação). Isso se dá considerando que os atos da administração presumem-se legítimos.

Exemplo de Ato perfeito, **inválido e ineficaz**: a Administração contratou com fraude na licitação – o contrato é inválido não há produção de efeitos.

d) Efeitos do ato administrativo

d.1) Efeitos típicos: são os principais efeitos desencadeados pela prática do ato.
EX: nomeação de candidato – o efeito típico é o provimento do ato; desapropriação do imóvel –

efeito típico é a aquisição da propriedade pelo Estado.

d.2) Efeitos atípicos: são os efeitos secundários do ato administrativo. Ex. desapropriação do imóvel de José – aquisição da propriedade pelo Estado é efeito típico; mas havia contrato de locação – a desocupação do imóvel pelo locatário é efeito secundário do ato.

3.3.4. ELEMENTOS OU REQUISITOS DO ATO ADMINISTRATIVO

Pelo critério clássico, encontramos tal classificação no artigo 2º, da Lei 4787/65 (Lei de Ação Popular). Esta lei dispõe que "se o ato é praticado inobservando seus elementos, haverá vício de legalidade, e o ato estará contaminado".

3.3.4.1. FORMA

Trata-se do **meio pelo qual se exterioriza a vontade**.

Regra quanto à forma: Princípio da solenidade (forma escrita). Quando se pratica um ato administrativo, em geral segue-se forma escrita. Todavia, alguns casos admitem a forma verbal, o sinal convencional e o silêncio como forma de exteriorização do ato administrativo, desde que haja previsão legal.

OBS: **A motivação** – **razões de fato e de direito** que serviram de suporte para a prática do ato – faz parte da forma.

VÍCIOS DE FORMA

Inicialmente, ressalte-se que os vícios do ato administrativo possuem uma classificação quadripartite:

a) ato inexistente – não conclui o seu ciclo de formação. As etapas previstas para a formação do ato não foram cumpridas;

b) meras irregularidades – defeito muito simples.

Embora não se obedeça integralmente o que a lei estabelece, não se afeta a regularidade do ato – não contamina o ato.

O ato, neste caso, não será comprometido em sua forma. Será válido;

c) vícios sanáveis – o administrador até pode anular, mas fazê-lo seria um exagero. Então, o administrador conserta o ato.

Esse conserto, no Direito Administrativo, recebe o nome de convalidação.

d) vícios insanáveis – deve ser considerado nulo. Neste caso, o ato deverá ser anulado.

EX de vícios de forma: a) não realizar o ato de forma escrita quando a lei exige esta; b) ausência de motivação; c) desapropriar um imóvel com resolução ao invés de decreto;

3.3.4.2. FINALIDADE

Também tem dois sentidos: a) sentido amplo: atender o interesse público (bem comum – princípio da indisponibilidade do interesse público; legalidade); b) sentido estrito – atender a finalidade prevista em lei. EX: punição do servidor que comete infração;

Vícios quanto à finalidade: a) abuso de poder tem duas vertentes: excesso de poder ou desvio de

finalidade. Haverá vício de finalidade quando o abuso de poder for **na modalidade desvio de finalidade**; b) impessoalidade; c) moralidade; d) MARIA CUERVO SILVA adverte que a finalidade está relacionada com a competência, vez que, ao definir competência do agente, esta resta vinculada à finalidade;

3.3.4.3. COMPETÊNCIA/SUJEITO

Não é competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma de direito.

A idéia de competência está relacionada à idéia de **divisão de trabalhos** por parte da Administração. Pode-se fixar a competência em razão da matéria, da hierarquia, do local de atividade ou do tempo de prestação. Caso esses critérios sejam extrapolados, pratica-se abuso de poder, **na modalidade excesso de poder.**

Vícios quanto à competência: 1) delegação e avocação não autorizada; 2) excesso de poder (não obediência dos critérios de competência) – abuso de poder – abuso de autoridade (4868/65); 3) impedimento ou suspeição – artigos 18 a 21, da Lei 9784/99; 4) Função de fato: ocorre quando o indivíduo pratica o ato **investido irregularmente no cargo, emprego ou função**; Se a situação tiver aparência de legalidade, o ato será considerado válido (terceiros de boa-fé, princípio da confiança). Ao contrário, **se evidente a incompetência, o ato será nulo**;

3.3.4.4. MOTIVO

Quando se pensa em motivo do ato, devem-se conjugar dois pressupostos: **pressupostos de fato + pressupostos de direito**. EX: Servidor comete infração e deve ser punido. Qual o pressuposto de fato?

Prática de conduta definida com infração; Qual o pressuposto de direito? Ter um estatuto que proíba aquela conduta; A junção desses dois pressupostos constitui o motivo. O motivo nada mais é do que a razão pela qual se atribua punição a servidor.

Vícios quanto ao motivo: 1) motivo falso ou inexistente; 2) móvel do agente contaminado; 3) motivo não declarado quando a declaração é obrigatória;

3.3.4.5. MOTIVAÇÃO

Justificativa do procedimento tomado. Segundo ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO CINTRA, a motivação pode ser: a) contextual – a justificativa está no próprio ato; b) aliunde – a justificativa está em instrumento diverso.

Prevalece que a motivação **é obrigatória** tanto nos atos vinculados quanto nos atos discricionários. Vide artigo 50 da Lei 9784/99.

3.3.4.6. MÓVEL

É a **intenção** – o que está na mente do agente. EX: Se um administrador baixa um decreto expropriatório para prejudicar um inimigo, **temos um vício ideológico/subjetivo.**

Isso **viola a finalidade do ato**, vez que não se busca o interesse público, mas o interesse pessoal. Da mesma forma, o motivo de direito também estará contaminado.

3.3.4.7. OBJETO OU CONTEÚDO

É tudo que cria, modifica, extingue e resguarda direitos. **É determinar o efeito jurídico imediato do ato**. Portanto, o objeto é **variável**.

CUIDADO: A finalidade é **invariável**, pois sempre irá buscar o interesse público;

Vícios quanto ao objeto: **1) objeto proibido por lei.** EX: Administração concede autorização para menores ingressarem em estabelecimento onde sua entrada é proibida; EX2: Administração permite que administrado pratique atividade ilícita; **2) Objeto impossível**. EX: Nomeação para cargo inexistente; **3) Objeto imoral.** DI PIETRO entende que uma das características do ato é que ela seja moral. CARVALHINHO, por sua vez, defende que a moralidade de ato é algo afeto à finalidade; EX de ato imoral: Parecer encomendado; **4) Objeto incerto.** EX: Desapropriação de bem indefinido.

3.3.4.8. CONVALIDAÇÃO E SANATÓRIA

CONVALIDAÇÃO: Previsão no artigo 55 da lei 9784/99 (lei de processo administrativo); Dentro desse instituto quer-se uma preservação da ordem de jurídica e social.

Espécies de convalidação:

a) Retificação: A convalidação procede da **mesma autoridade que emitiu o ato inválido**; A própria autoridade que fez o ato inválido o conserta, ratifica;

b) Confirmação: A convalidação procede de outra autoridade que não a que emitiu o ato inválido;

c) Saneamento: A convalidação resulta de um ato particular;

Nessas três hipóteses, **sai-se de um ato inválido para se formar um ato válido**;

SANATÓRIA OU CONVERSÃO: Tem-se um ato solene que não preenche os requisitos legais e é transformado em um ato mais simples que passa a preencher os requisitos.

3.3.5. Classificação dos atos administrativos

1. Quanto aos destinatários:

a) **Atos administrativos gerais:** ato geral é aquele que atinge a coletividade. EX: a velocidade máxima de 80 quilômetros em uma rodovia/avenida é ato geral, impessoal, abstrato, aplicado a coletividade como um todo.

b) **Atos administrativos individuais:** ato individual é aquele que tem um destinatário determinado. Ex. Nomeação da Maria para o cargo X.

2. Quanto ao alcance do ato:

a) **Atos internos:** são atos administrativos que produzem efeitos internos, dentro da administração. EX: uso de determinada cor de caneta para elaboração de certidões.

b) **Atos externos:** são atos administrativos que produzem efeitos externos. EX: horário de funcionamento do órgão público.

3. Quanto ao grau de liberdade:

a) **Ato vinculado:** é aquele em que todos seus elementos estão previstos em lei.

b) **Ato discricionário:** é aquele em que há certo juízo de valor, liberdade do administrador.

4. Quanto a Formação:

a) **Ato simples:** é o ato que depende de uma única manifestação de vontade.

b) **Ato composto:** são necessárias duas manifestações de vontade, que ocorrem no mesmo órgão. O subordinado pratica o ato e o chefe confirma essa manifestação.

São duas manifestações em um mesmo órgão. A primeira manifestação é principal, enquanto a segunda é secundária, apenas para ratificar a anterior.

c) **Ato complexo:** são necessárias duas manifestações de vontade, que ocorrem em órgãos distintos.

Estes órgãos estão em patamar de igualdade (ambas as manifestações têm a mesma força).

3.3.6. Formas de extinção dos atos administrativos

a) Cumprimento de seus efeitos: a.1) advento de termo final; a.2) realização de execução material; a.3) esgotamento de seu conteúdo jurídico; EX: O servidor pleiteia férias, fazendo uma solicitação para seu superior. Estas são concedidas no mês de dezembro. Após o fim das férias, o ato esgota seu conteúdo jurídico;

b) Extinção em razão do desaparecimento do sujeito: Suponha que certo indivíduo passe em um concurso, mas morre logo após a nomeação. Ocorre, portanto, a vacância do cargo por desaparecimento do sujeito;

c) Extinção em razão do desaparecimento do objeto: Imagine-se que se tem uma fábrica poluente, que está jogando resíduos tóxicos na atmosfera.

A Administração Pública verifica a ocorrência do ato lesivo mediante o exercício do poder de polícia e resolve fechar interditar fábrica.

No entanto, se o dono do estabelecimento resolve desativá-lo definitivamente, ocorre extinção em razão do desaparecimento do objeto.

d) Renúncia: O sujeito só renuncia o que lhe é favorável. **Conceito: Há, pelo beneficiário, uma rejeição de situação jurídica favorável que gozava como conseqüência daquele ato**; EX: Agente público renuncia cargo de secretário de Estado;

e) Retirada: e.1) Anulação – A Administração e o Judiciário podem anular os atos administrativos ilegais/ilegítimos; **e.2) Revogação** – Retirada por inconveniência e inoportunidade; **e.3) Cassação** – É a retirada do ato quando o destinatário descumpre condições que deveria continuar atendendo. EX: A Administração dá ao particular a licença para desempenhar a função de hotel. Suponha-se que, no lugar do hotel, o administrado faz uma “casa de massagem”. Nesse caso, o ato tem natureza sancionatória; **e.4) Caducidade** – **retirada do ato em razão de superveniência de norma que não mais admite situação antes permitida** e concedida pelo ato; EX: Dá-se uma permissão ao particular para utilização de bem público. Empós, surge uma lei que não mais permite essa utilização. Ocorre a caducidade do ato concedido;

f) Derrubada ou contraposição – É a retirada do ato em razão do advento de outro que impede a produção de efeitos pelo primeiro.

3.4. Serviços públicos

3.4.1. Atividades estatal no domínio econômico X Serviços Públicos

O campo do domínio econômico está disciplinado nos artigos **170 a 174, da CF**. Em princípio, é atinente ao setor privado.

O **serviço público** encontra-se nos **artigo 175 e 176, da CF**. Em princípio, é desempenhado pelo próprio do Estado.

Há um abismo separando o domínio econômico do serviço público, já que o Estado só deve atuar na economia em situações excepcionais.

Segundo artigo 173, CF, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só pode ocorrer por **imperativos da segurança nacional** ou **relevante interesse coletivo**.

São casos raros porque o Estado abandona sua situação de superioridade e passa a atuar no mercado, área própria da iniciativa particular.

Toda atividade econômica está em regime de Direito Privado. Quando o Estado explora atividade econômica ele atuará sob o regime privado. Essa atuação ocorre por meio de **Empresas Públicas** e **Sociedades de Economia Mista**, que são as pessoas da Administração Indireta de Direito Privado.

Não há como a Administração Direta explorar atividade econômica.

3.4.2. Regime constitucional do serviço público

> Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou **sob regime de concessão ou permissão**, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.
> Parágrafo único. A lei disporá sobre:
> I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;
> II - os direitos dos usuários;
> III - política tarifária;
> IV - a obrigação de manter serviço adequado.

O regime constitucional do serviço público encontra guarida no artigo 175 da Constituição Federal. A Administração, segundo o dispositivo, pode prestar o serviço público diretamente ou sob regime de concessão ou permissão (veja tópico específico abaixo explicando os detalhes de cada forma de prestação indireta).

A concessão ou permissão sempre será precedida de licitação na modalidade concorrência, cujos tipos serão escolhidos conforme o serviço a ser prestado.

Por fim, a Constituição Federal estabelece alguns pontos sobre concessão e permissão que devem ser regidas lei.

A lei que rege a concessão e permissão de serviços públicos é a lei 8987/95.

3.4.3. Conceito

O conceito de serviço público possui cinco elementos, quais sejam:

a) Atividade material – Elemento fundamental. Quer dizer que o serviço público **exige uma ação concreta do administrador**. Isso exclui as atividades jurídicas e intelectuais.

b) Atividade ampliativa – O serviço público aumenta a esfera de interesse do particular, criando utilidades e comodidades.

Uma atividade restritiva nunca pode ser considerada serviço público. EX: Segurança pública jamais poderá ser serviço público. Trata-se de um poder de polícia. Segurança pública não aumenta esfera de interesses de ninguém.

c) Prestado pelo Estado ou por seus delegados

No Brasil, não existe prestação de serviço público espontânea por parte do particular, sem uma delegação estatal.

d) Prestado sob regime de Direito Público

O regime público é uma prestação, vantagem, garantia do usuário.

As prerrogativas públicas próprias do serviço público são criadas em favor do usuário, do destinatário final do serviço.

OBS: Sempre que houver prestação de serviços públicos, a responsabilidade é objetiva. O usuário tem a garantia de que se ele sofrer um prejuízo na prestação do serviço, sempre será ressarcido, independente de culpa do prestador. Muda o prestador, a garantia continua. O usuário sempre estará lá na ponta se beneficiando.

OBS2: A responsabilidade é **direta do prestador**, e o Estado responde em **caráter subsidiário** (o Estado sempre é **garantidor da indenização**).

e) Os serviços públicos atendem a necessidades essenciais da sociedade

Trata-se da visão clássica de que para ser serviço público uma atividade deve ser intrinsecamente essencial para a coletividade (HELY LOPES MEIRELES).

Só que hoje é uma visão superada, **porque ela não resiste a uma análise prática dos serviços públicos brasileiros**. Predomina o entendimento de que o critério fundamental para a qualificação de uma atividade como serviço público não é a sua essencialidade, mas a **previsão legal ou constitucional do seu exercício como um dever do Estado (decisão legislativa), atribuindo-lhe um regime jurídico público (critério formal)**. EX: Telefonia fixa é serviço público e telefonia móvel é atividade econômica. Se a telefonia fixa quebrar, o Estado tem o dever de continuidade. Se a telefonia móvel quebrar, os clientes ficam prejudicados.

3.4.4. Espécies de serviço público

Serviços "uti universi" – São indivisíveis, criando **vantagens difusas para a coletividade**. **Não podem ser dados em concessão/permissão** (devem ser prestados diretamente pelo Estado), e **nem taxados**.

Não criam vantagem individual para cada usuário.

São serviços considerados **despesas gerais** custeadas por impostos. EX: Coleta de lixo. Não pode haver concessão ou permissão para coleta de lixo.

Serviço "uti singuli" – São específicos e divisíveis: criam vantagens fruíveis individualmente pelos usuários.

Podem ser dados em permissão ou concessão. Se o Estado prestar diretamente, poderá **cobrar taxa**.

3.4.5. Titularidade

Por definição, somente pessoas jurídicas de direito público podem titularizar o serviço. É impossível que o serviço seja titularizado por uma pessoa jurídica de direito privado, que está submetido ao regime privado.

Nos serviços públicos prestados por pessoas jurídicas de Direito Privado (EXs: Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista), o prestador só tem a titularidade da prestação, não do serviço. EX: Correios. É uma Empresa Pública da União. Sendo assim, não tem titularidade sobre o serviço postal.

Tem titularidade sobre a prestação de serviço postal. A titularidade do serviço postal cabe a União.

3.4.6 Formas de prestação

Em alguns casos, a forma de prestação é determinada pela CF. EX: Nos serviços públicos de rádio e TV, a Constituição determina que o serviço seja prestado pelo Estado e também por particulares (artigo 21, XII, *a*). Quando não houver ordem Constitucional, a decisão cabe ao legislador. Já nos casos específicos de permissão e autorização, a decisão cabe ao Executivo.

Prestação direta – É aquela que está a cargo do próprio Estado (Administração Direta).

Divide-se em duas categorias: **a) Prestação direta feita pelo aparelho estatal**. EX: Serviço Jurisdicional; **b) Prestação direta terceirizada** – feita com o apoio de particulares. Estado faz uma licitação e quem ganhar o certame assume um contrato de prestação de serviços com o Estado. Ressalte-se que o prestador de serviços assina um contrato com o Estado e não tem relação direta com o usuário. EX: Coleta de lixo. A empresa de coleta de lixo atua em nome de Estado. Não tem relação com o usuário. **Se um caminhão de lixo bate em particular, este deve ingressar com ação diretamente contra o Estado**. Isso que diferencia a prestação direta da concessão/permissão. Nesse último caso, a concessionária/permissionária que responde pelos atos lesivos.

ATENÇÃO: Em qualquer caso que se tenha prestação direta de serviço público, a prestação é feita em nome do Estado.

Prestação indireta – Tem-se outra pessoa prestando serviço, que não a Administração Direta.

A prestação indireta também se divide em duas: **a) prestação indireta por outorga** – O Estado cria a instituição que executará o serviço. EX: Autarquias e Fundações Públicas; **b) prestação indireta por delegação** – Neste caso, quem presta o serviço público não é uma instituição criado pelo Estado.

É uma instituição privada selecionada pelo Estado por meio de licitação. Existem três regimes de prestação indireta por delegação: concessão, permissão e autorização.

OBS: Concessionários, permissionários e autorizatários prestam serviço público em nome próprio, isto é, tendo **relação jurídica direta com o usuário**, razão pela qual, se causarem dano, a responsabilidade é direta deles.

OBS2: Quando houver prestação indireta de serviço público **por delegação**, a remuneração paga pelo usuário tem natureza jurídica de tarifa/preço público. **Ressalte-se que como tarifa não é tributo.**

3.4.7. Concessão X Permissão X Autorização

Concessão é um **contrato**. Portanto, é bilateral. Significa que o concessionário **tem direitos contra o Poder concedente**.

Qual o principal direito do concessionário? Como a concessão é sempre feita por tempo determinado, sua rescisão **gera indenização ao particular**.

Segundo a doutrina, permissão é **ato unilateral** (o permissionário não tem direitos contra o Estado), discricionário e precário (a permissão pode ser revogada a qualquer tempo).

ATENÇÃO: De acordo com o artigo 40 da Lei 8987, a permissão é um **contrato de adesão**. Portanto, segundo a lei, não se trata de ato unilateral, mas de contrato de adesão.

Existem dois tipos de permissão, a saber: **a) a permissão típica** – é outorgada por prazo indeterminado, de modo que sua revogação não gera direito à indenização; **b) permissões anômalas** – outorgadas por prazo determinado. Se revogadas antecipadamente, ensejam direito à indenização (**desde que o permissionário não concorra para a extinção**).

A autorização **tem a mesma natureza jurídica da permissão** (unilateral, discricionária e precária).

Diferença da permissão para a autorização – A permissão é outorgada no predomínio do interesse público. A autorização, no predomínio do interesse privado.

3.5. Servidores públicos

3.5.1. Conceito de agentes públicos

É uma designação genérica usada para fazer referencia a **todas as pessoas que mantenham vínculo profissional ou funcional com o Estado**, ainda que temporariamente e/ou sem remuneração. **Para ser agente público, basta exercer função administrativa**.

O gênero “agentes públicos” comporta as seguintes espécies:

a) Agentes políticos
b) Ocupantes de cargo em comissão (comissionários)
c) Contratados temporários
d) Agentes militares
e) Particulares em colaboração com a administração – refere-se a quem trabalha de graça ou com uma função transitória
f) Empregados públicos
g) Servidores estatutários (servidores públicos em sentido estrito)

3.5.2. Agentes Políticos

Exercem “múnus público” (função pública, tarefa pública) de alta direção do Estado.

São responsáveis por uma parcela de soberania do estado.

A CF não delimita expressamente quem são os agentes políticos. Portanto, a doutrina varia bastante de um autor para outro. EX de agentes políticos: parlamentares, chefes do executivo.

3.5.3. Ocupantes de cargos em comissão

São cargos declarados em lei como de livre nomeação e livre exoneração. Livre nomeação significa sem concurso. Livre exoneração significa exoneração imotivada. O motivo não precisa ser declarado.

OBS: Cargo em comissão (cargo de confiança) ≠ função de confiança

Função de confiança só pode ser exercida por servidor pertencente à determinada carreira. Ex: Procurador–chefe na Advocacia Geral da União.

Cargo em comissão (cargo de confiança) não exige vinculação especial com o serviço público.

Segundo a CF (art. 37, V), os cargos em comissão estão reservados a atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Como todo cargo, os cargos em comissão **devem ser criados por lei**, mas nunca serão titularizados (como os cargos dos estatutários). Apenas serão **ocupados** por quem os exerce.

3.5.4. Contratados Temporários

O art. 37, IX, da CF determina que os contratos temporários devam ser firmados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Esse dispositivo foi regulamentado pela lei 8745/93.

ATENÇÃO: É uma lei aplicável somente às pessoas jurídicas de direito público do âmbito federal. Portanto, trata-se de um **regime público de contratação especial** em relação à lei 8112/90 (que não é aplicável aos temporários).

Outrossim, é um regime que, em decorrência da sua especialidade, **não comporta a contratação celetista**.

Não há concurso público, mas processo seletivo simplificado, cuja realização é dispensada nos casos de calamidade pública ou emergência ambiental.

Geralmente, nesse processo seletivo simplificado, há uma preferência a candidatos com maior necessidade financeira.

O prazo máximo dessa contratação é de 4 anos, o que torna essa lei visivelmente inconstitucional, porque não há urgência que dure todo esse tempo.

3.5.5. Agentes Militares

Trata-se de uma vinculação estatutária (significa que a relação não é contratual, pois as regras estão pré-definidas e são insuscetíveis de modificação bilateral).

Estatuto é um conjunto pré-definido de regras. Uma pessoa adere ao estatuto, mas nunca tem condições de alterar as regras deste.

Há uma **expressa proibição de sindicalização, greve e filiação partidária** dos agentes militares.

3.5.6. Particulares em colaboração

Exercem função pública. Em regra, transitoriamente e sem remuneração.

Exemplos:

a) **requisitados de serviços** (mesários e corpo de sentença do tribunal do júri);
b) **contratados por locação civil de serviços**. Ex: jurista para emitir parecer.
c) **concessionários e permissionários.**
d) delegados de função ou ofício público – **titulares de cartório**.

3.5.7. Empregados Públicos

Ingressam mediante concurso para ocupar empregos públicos, mantendo com o Estado uma vinculação contratual regida pela CLT.

Estão parcialmente submetidos às regras da CLT. Há uma sujeição parcial ao regime celetista, pois o vínculo sofre uma influencia derrogatória de regras públicas, quanto à **forma de ingresso** e ao **modo de desligamento**.

O regime de emprego público é obrigatório nas empresas estatais (Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, Fundações privadas e subsidiárias).

Segundo a unanimidade da doutrina, empregados públicos não podem ser demitidos sem justa causa (em razão do dever de motivação dos atos administrativos), além de ser obrigatório garantir o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo instaurado para demissão.

3.5.8. Servidores Públicos Estatutários

3.5.8.1 CONCEITO E CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Trata-se do indivíduo que atua em Pessoa Jurídica de Direito Público (Administração direta, autarquias e fundações públicas). Devem estar submetidos a um **regime único**, que pode ser celetista ou estatutário.

É importante salientar que a emenda constitucional 19, de 1998, havia alterado a redação original da Constituição Federal, estabelecendo regime múltiplo para contratação de servidores, isto é, os regimes celetista e estatutário passaram a poder conviver juntos em um mesmo ente.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2135, afastou a redação dada pela emenda, e restabeleceu o regime jurídico único, ressalvando os celetistas que firmaram contrato na vigência da emenda.

Na seara federal, este regime é estatutário, regido pela lei 8.112, de 1990 (Estatuto dos Servidores Públicos da União).

Ressalte-se que a expressão “funcionário público”, que se encontra em alguns doutrinadores, refere-se ao servidor público estatutário titular de cargo. No entanto, essa expressão não é mais utilizada pela lei e pela Constituição Federal. Portanto, é bom evitar a terminologia.

3.5.8.2. FORMA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO

O indivíduo ingressa no serviço público mediante concurso público, segundo os ditames do artigo 37, II, da Constituição Federal.

Trata-se de um procedimento administrativo, externo e concorrencial, realizado sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Externo porque envolve particulares.

Concorrencial em razão de se tratar de uma disputa, sendo restritivo, já que termina em decisão administrativa que limita os direitos dos reprovados.

Sua realização é um imperativo da isonomia, impessoalidade, moralidade, legalidade e eficiência.

Concurso resta necessário apenas para **estatutários e empregados públicos**.

A CF fala em dois tipos: "**provas**" e "**provas e títulos**", a depender da complexidade da função.

A validade de concurso é de **até dois anos, prorrogável uma vez por igual período**.

Consigne-se que a decisão da validade de concurso é discricionária da Administração Pública, mas existe vinculação quanto à prorrogação. Esse prazo de até dois anos corre a partir da homologação do concurso.

ATENÇÃO: Como regra, a aprovação em concurso gera simples expectativa de direito à nomeação (situação subjetiva ativa desprovida de exigibilidade). No entanto, existem situações em que o candidato passa a ter direito subjetivo à nomeação, quais sejam:

a) O edital indicar número de vagas e o candidato for aprovado dentro desse número.

b) Preterição de ordem.

c) Contratação temporária para a função a ser provida pelo concurso.

Posse – É um ato jurídico, formalizado pela assinatura do termo de posse. O prazo para o servidor tomar posse no cargo para o qual prestou é de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento.

Exercício – É o início efetivo do desempenho das atribuições. O servidor empossado tem 15 dias para entrar em exercício.

3.5.8.3. FORMA DE AQUISIÇÃO DE ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO

"A estabilidade é instituto há muito existente em nosso ordenamento, tendo como finalidade principal **assegurar aos ocupantes de cargos públicos de provimento efetivo uma expectativa de permanência no serviço público**, desde que adequadamente cumpridas suas atribuições" (ALEXANDRINO; PAULO, 2011, p. 322).

A Constituição Federal tratou da estabilidade em seu artigo 41.

Pelo texto originário da Constituição Federal, a estabilidade foi conferida aos servidores públicos nomeados em virtude de concurso público **após dois anos de efetivo exercício**. Esse prazo é denominado estágio probatório, em que devem ser avaliadas as características do indivíduo ao exercer seu cargo, a saber: assiduidade, habilidade, efetividade, dentre outros.

A partir da emenda constitucional nº 19, de 1998, a estabilidade passou a ser conferida somente após três anos de efetivo exercício.

Esta emenda também acrescentou o parágrafo 4º ao artigo 41 da Constituição. Passou a exigir, como condição para a aquisição da estabilidade, a aprovação do servidor em uma **avaliação especial de desempenho,** feita por comissão instituída para esse fim.

Portanto, após a EC 19/98, passaram a ser requisitos concomitantes e cumulativos para a aquisição de estabilidade os seguintes:

a) Concurso público;

b) Cargo público de provimento efetivo (**não pode ser cargo em comissão ou contratação temporária**);

c) Três anos de efetivo exercício;

d) Aprovação em avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade;

3.6. Questões

1ª) Disserte sobre os princípios jurídicos expressos na Constituições e sobre as "pedras de toque" do Direito Administrativo.

2ª) Diferencie descentralização de desconcentração.

3ª) Analise a seguinte proposição, marcando certo ou errado:

A finalidade dos atos administrativos é sempre um elemento vinculado, pois o fim desejado por qualquer ato administrativo é o interesse público.

4ª) Quanto ao Ato Administrativo, analise os itens abaixo:

I. A Administração Pública, como instituição destinada a realizar o Direito e a propiciar o bem comum, não pode agir fora das normas jurídicas e dos princípios constitucionais explícitos e implícitos, nem relegar os fins sociais a que sua ação se dirige. A legitimidade da atividade decorre do respeito à lei e aos referidos princípios, razão pela qual não são passíveis de invalidação.

II. São requisitos necessários à formação do ato administrativo: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Tais componentes, pode-se dizer, constituem a infraestrutura do ato administrativo, seja ele vinculado ou discricionário, simples ou complexo, de império ou de gestão.

III. Ato Administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações somente aos seus administrados, não a si própria.

IV. Os atos administrativos, como emanação do Poder Público, trazem em si certos atributos que os distinguem dos atos jurídicos privados e lhes emprestam
características próprias e condições peculiares de atuação. São atributos do ato administrativo: a presunção de legitimidade, a imperatividade e a auto-executoriedade.

Está(ão) **CORRETO(S**):

a) Apenas o item I.

b) Apenas o item III.

c) Apenas os itens I e III.

d) Apenas os itens II e IV

5ª) Assinale certo ou errado de acordo com o enunciado abaixo:

Os serviços prestados por pessoas jurídicas em regime de concessão ou permissão, ainda que para satisfazer as necessidades coletivas, não são considerados serviços públicos, já que não são prestados diretamente pelo Estado.

6ª) Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento da seguinte norma:

a) para as nomeações de cargo em comissão, é necessário concurso público de títulos.

b) o prazo de validade do concurso público de provas será de dois anos, improrrogáveis.

c) a nomeação do candidato aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos obedecerá à ordem de classificação.

d) durante o prazo improrrogável previsto no edital do concurso, o candidato aprovado não será convocado com prioridade sobre os novos concursados.

7ª) Disserte sobre a forma de ingresso e aquisição de estabilidade no serviço público.

3. ERRADO; 4. D; 5. ERRADO; 6. C

4. DIREITO EMPRESARIAL

Bibliografia indicada

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. **Direito Empresarial Esquematizado.** São Paulo: Editora Método, 2011.

Bibliografia complementa

COÊLHO, Fábio Ulhôa. **Manual de Direito Empresarial**. São Paulo: Saraiva, 2011.

Legislação indicada

Código Civil – artigos 966 e ss.

Lei das Sociedades Anônimas

Lei da propriedade industrial (9.279)

4.1. Breve evolução histórica do Direito Empresarial (Teoria dos atos de comércio x Teoria da Empresa)

O Código Comercial de 1850, que teve a ampla maioria de seu conteúdo revogada pelo Código Civil de 2002, adotava a Teoria dos Atos de Comércio, de origem francesa. Eis o motivo pelo qual até pouco tempo atrás a disciplina era chama de Direito Comercial.

De acordo com a Teoria dos Atos de Comércio, o Direito Comercial regularia, portanto, as relações jurídicas que envolvessem a prática de alguns atos definidos em lei como **atos de comércio**, que podiam ser praticados por comerciantes (pessoas físicas) ou sociedades comerciais (pessoas jurídicas).

Todavia, a pessoa física ou jurídica que almejasse ser classificada como comerciante ou sociedade comercial deveria reunir as seguintes características: habitualidade na atividade, finalidade lucrativa e prática de um dos atos de comércio.

Os atos de comércio estavam elencados no Regulamento 737 de 1850.

Ressalte-se que poucos os atos eram considerados como **atos de mercancia**, excluindo-se da prática comercial uma série de atividades de suma importância. EX: Prestação de serviços, atividade imobiliária.

Esse era o maior problema do Direito Comercial. Tratava-se de análise meramente objetiva: se o ato não estivesse elencado no regulamento, não seria considerado comerciante ou sociedade comercial.

Com o advento do Código Civil, revogou-se a primeira parte do Código Comercial de 1850 (que dispunha sobre o comerciante e a sociedade comercial). O novo Código Civil adotou uma nova teoria chamada **Teoria da Empresa***,* de origem Italiana, vindo para modificar a situação existente.

O Direito Comercial deixou de ser o direito do comerciante ou o direito dos atos de comércio para se tornar o direito da empresa, alcançando um número muito maior de relações jurídicas (o ramo do Direito passou a se chamar **Direito Empresarial**).

A análise deixou de ser objetiva. “Qualquer atividade econômica, desde que exercida empresarialmente, está submetida à disciplina das regras do direito empresarial” (RAMOS, 2001, p. 9).

4.2. Conceito de Empresário

O artigo 966 do Código Civil traz o conceito de empresário. **Esse conceito se aplica tanto para a pessoa natural (empresário individual) como para a pessoa jurídica (sociedade empresária)**.

> Art. 966. Considera-se empresário quem **exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços**.

Essa expressão "profissionalmente" significa **habitualidade**. A "atividade econômica", por sua vez, denota **finalidade lucrativa**. Portanto, **empresário é aquele que busca lucro com habitualidade**.

Além disso, a atividade deve ser "organizada", isto é, **o empresário deve ser aquele que articula os fatores de produção** (capital, mão-de-obra, insumos e tecnologia).

Por fim, a atividade deve ser voltada para a produção e circulação demonstra a abrangência da Teoria da Empresa. Qualquer atividade econômica poderá, em princípio, submeter-se ao regime jurídico empresarial, bastando que seja exercida profissionalmente, de maneira organizada e com o intuito lucrativo. Sendo assim, a expressão produção ou circulação de bens ou de serviços deixa claro que nenhuma atividade econômica está excluída, a priori, do âmbito de incidência do Direito Empresarial.

4.2.1 Agentes econômicos excluídos do conceito de empresário

Os agentes econômicos excluídos do conceito empresário podem ser assim enquadrados: a) Se for pessoa natural, é profissional **autônomo**; b) Se for pessoa jurídica, será uma **sociedade simples** (antes do Código Civil de 2002, essas sociedades eram denominadas sociedades civis).

A definição de sociedade simples encontra-se no artigo 982 do Código Civil, a saber:

> Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito aregistro (art. 967); **e, simples, as demais**.
>
> Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações; e, simples, a cooperativa.

Portanto, a sociedade simples é aquela que não tem por objeto atividade própria de empresário. Atente-se, também, para a regra do parágrafo único do mesmo artigo, que estabeleceu a seguinte regra: **independentemente do objeto (envolva atividade empresário ou não), a sociedade por ações sempre será empresária e a cooperativa sempre será simples**. Tratou-se de uma opção política do legislador.

Consigne-se, outrossim, que o artigo 966, §único, do CC, traz uma regra de suma importância para o tema em foco, qual seja: "Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual científica, literária ou artística, ainda que com ajuda de colaboradores, **salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa**".

Este dispositivo trata do profissional liberal. EX: Advogado, contador, engenheiro, arquiteto (científica), jornalista, escritor (literária), ator, desenhista (artística).

Em regra, esses profissionais não exercem atividade empresarial, devendo ser excluídos do conceito de empresário. No entanto, o quadro pode se alterar caso haja, no exercício da profissão, presença de elemento empresa.

EX: Uma clínica veterinária quer engloba, além dos serviços veterinários usuais, pet shop (vende comida, roupinha, etc), hotel para cachorro, espaço para evento de cachorro e inúmeras outras atividades. Neste caso, tem-se atividade intelectual? Sim, mas a atividade intelectual não está sozinha. Ela se tornou um componente oferecido junto com as demais atividades, que são empresariais. **A atividade intelectual tornou-se elemento de empresa. Então, a clínica passou a qualidade de empresa**.

4.3. Empresário individual

Empresário individual é a pessoa física que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços.

4.3.1. Requisitos para o desempenho da atividade empresário pelo empresário individual

a) Estar em pleno gozo da capacidade civil

Em regra, o incapaz não pode ser empresário individual.

No entanto, se o incapaz encontra-se emancipado (ver capítulo de Direito Civil), pode exercer a atividade empresarial.

Já se o incapaz não se encontra emancipado, não será possível dar início a uma atividade empresarial, mas o Código Civil permite que ele possa continuar uma empresa após a interdição civil ou a sucessão hereditária, conforme se observa a seguir:

> Art. 974, CC. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança. § 1º Nos casos deste artigo, precederá autorização judicial, após exame das circunstâncias e dos riscos da empresa, bem como da conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvidos os pais, tutores ou representantes legais do menor ou do interdito, sem prejuízo dos direitos adquiridos por terceiros. § 2º Não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que o incapaz já possuía, ao tempo da sucessão ou da interdição, desde que estranhos ao acervo daquela, devendo tais fatos constar do alvará que conceder a autorização.

Para que o incapaz possa **continuar a empresa** são necessários requisitos:

*** Deve estar devidamente assistido ou representado**;

* Deve haver **Autorização judicial**;

> Art. 974, §1º: § 1º Nos casos deste artigo, precederá autorização judicial, após exame das circunstâncias e dos riscos da empresa, bem como da conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvidos os pais, tutores ou representantes legais do menor ou do interdito, sem prejuízo dos direitos adquiridos por terceiros.

b) responsabilidade ilimitada

Segundo o princípio da unidade patrimonial, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica possuem um único patrimônio.

Assim, se o empresário individual é uma pessoa física, ele terá um único patrimônio, que não pode ser separado de seu patrimônio pessoal.

Diante disso, se o empresário individual possui dívidas, as dívidas podem recair tanto sobre o bem do empresário individual como da pessoa física.

O reverso também é verdadeiro, havendo possibilidade de os bens da pessoa jurídica responderem pelas dívidas da pessoa física.

c) Não possuir impedimento legal

A lei que determina os impedimentos legais ao exercício das atividades empresariais. EX: Membro do MP pode ser quotista ou acionista de empresa, mas não pode administrá-la.

4.3.2. Empresário casado

a) Averbação de atos civis na Junta Comercial

Tudo que ocorrer com o empresário casado deve ser comunicado e averbado na Junta Comercial. EX: separação, divórcio, ato de reconciliação, pacto antenupcial.

> Art. 979, CC. Além de no Registro Civil, serão arquivados e averbados, no Registro Público de Empresas Mercantis, **os pactos e declarações antenupciais do empresário**, o título de doação, herança, ou legado, de bens clausulados de incomunicabilidade ou inalienabilidade.
>
> Art. 980. **A sentença que decretar ou homologar a separação judicial do empresário e o ato de reconciliação não podem ser opostos a terceiros, antes de arquivados e averbados no Registro Público de Empresas Mercantis**.

b) Alienação de Imóveis:

> Art. 978, CC – O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, **qualquer que seja o regime de bens**, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa (destinado a atividade empresarial) ou gravá-los de ônus real.

É necessário observar que o art. 1.647 do CC dispõe que nenhum dos cônjuges pode, sem a autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, alienar ou gravar de ônus real bem imóvel. Essa é a regra geral do Direito Civil.

No entanto, há regra diferenciada quanto ao empresário individual. No que tange a este, **não se faz necessária** autorização do cônjuge para alienação de bens imóveis, qualquer que seja o regime de bens escolhido pelos cônjuges.

4.4. Principais Sociedades Empresárias

4.4.1. Sociedade limitada

a) Legislação aplicável – Artigo 1052 e seguintes do Código Civil.

Há um capítulo do Código Civil tratando de sociedade limitada. Na omissão deste capítulo, aplica-se, como regra geral, as regras das sociedades simples.

DETALHE: **É possível colocar no contrato social da LTDA que**, ao invés de incidir as regras da sociedade simples em caso de omissão, **incida supletivamente a lei de S/A**.

Importante lembrar que só é possível a aplicação das regras da sociedade anônima em caso de previsão expressa.

b) Sócio

Tanto pessoa natural como pessoa jurídica podem ser sócios.

O artigo 974, §3º, diz que o menor pode ser sócio de uma sociedade, desde que preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: b.1) O menor tem que estar devidamente assistido ou representado; b.2) Ele não pode exercer administração; b.3) o capital social deve estar totalmente integralizado.

OBS: O artigo 977 diz que é possível sociedade entre cônjuges, salvo em dois casos: a) Regime de separação obrigatória; b) Regime de comunhão universal de bens.

c) Cotas sociais

c.1) **Formas de integralização** – Dinheiro, bens e créditos.

Segundo o Artigo 1055, §2º, do CC, está **vedada** a integralização com prestação de serviços na sociedade limitada, não importa se a limitada é simples ou empresária.

c.2) De acordo com o artigo 1055, do CC, as cotas podem ser **iguais ou desiguais**.

> Art. 1.055, CC. O capital social divide-se em quotas, **iguais ou desiguais**, cabendo uma ou diversas a cada sócio.

c.3) **Cessão de cotas** – Artigo 1057, CC – Se o sócio de uma sociedade limitada e quiser transferir suas cotas para alguém que já é sócio, não é preciso da autorização de ninguém.

Agora, se o sócio e quiser transferir suas cotas para um terceiro estranho, que não é da sociedade, isso só é possível se não houver a oposição de mais de um quarto do capital social, ou seja, ¾ do capital social deve aprovar a cessão;

> Art. 1.057. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua quota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social.
>
> Parágrafo único. A cessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiros, inclusive para os fins do parágrafo único do art. 1.003, a partir da averbação do respectivo instrumento, subscrito pelos sócios anuentes.

d) Responsabilidade dos sócios – Artigo 1052, CC.

> Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio **é restrita ao valor de suas quotas**, **mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social**.

4.4.2. Sociedade anônima

a) Conceito

Sociedade anônima é a sociedade cujo **capital social está dividido em ações**. O indivíduo que tem ações de uma sociedade anônima torna-se sócio desta.

b) Principais características:

A sociedade anônima é **sociedade institucional**.

De acordo com o art. 982, parágrafo único, a sociedade anônima **sempre será considerada sociedade empresária**.

O registro da sociedade anônima é **sempre efetivado na Junta Comercial**.

c) Espécies de sociedades anônimas:

Têm-se as chamadas companhias abertas e as companhias fechadas.

Companhia aberta é aquela em que seus valores mobiliários são admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários.

Companhia fechada é aquela em que seus valores mobiliários não são admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários.

d) Valores mobiliários são títulos de investimento (papéis) que a S/A emite para obtenção dos recursos que necessita. Exemplos de valores mobiliários: ações e debêntures.

Nós temos o mercado primário e o mercado secundário de valores mobiliários.

O **mercado mobiliário primário** é aquele em que a relação entre a S/A e o investidor é direta.

Já o mercado **mobiliário secundário** é aquele em que o acionista de S/A negocia suas ações com outro investidor. Ocorre no mercado de balcão ou na bolsa de valores.

e) Bolsa de valores: a Bolsa de Valores tem a finalidade de aumentar o fluxo de negociação dos valores mobiliários. É uma **associação civil de Direito Privado ou uma sociedade anônima constituída por corretoras de valores mobiliários de uma mesma base territorial** que, autorizada pela comissão de valores mobiliários, organiza e mantém o pregão de ações e outros valores mobiliários.

f) Mercado de balcão: é toda operação realizada fora da bolsa de valores. Ex. compra de ações diretamente de sociedades corretoras ou de uma instituição financeira.

4.5. Direito de propriedade intelectual

4.5.1. Aspectos introdutórios

A propriedade intelectual está subdividida em direito autoral (protegido pelo direito civil) e propriedade industrial (protegido pela Lei 9.279/96). A finalidade dessa lei é garantir a exclusividade de uso de alguns bens e incentivar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico.

A remuneração da licença de uso dos bens de propriedade industrial é que chamamos de *royalties*.

4.5.2. Bens protegidos por esta lei

Invenção Modelo de utilidade Desenho industrial Marca

A própria lei, ao classificá-los, diz que são bens móveis.

Além de proteger esses bens, a lei também cuida da **repressão à falsa indicação geográfica** e à **concorrência desleal**.

Art. 2º, Lei 9279/96. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial; III - concessão de registro de marca; IV - repressão às falsas indicações geográficas; e V - repressão à concorrência desleal.

4.5.3. Exclusividade

Busca proteger a exclusividade de uso.

Para isto, é necessário produção própria e licença de uso (a remuneração decorrente dela chama-se de “royalties”).

A invenção e modelo devem ser **patenteados**, enquanto o desenho industrial e a marca têm **registro**.

→ Invenção
→ Modelo de Utilidade } Patente

→ Desenho Industrial
→ Marca } Registro

Ambos são obtidos junto a um órgão chamado **INPI** – Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

O INPI é uma autarquia federal, com sede no Rio de Janeiro.

4.5.4. Prazos de duração da exclusividade

- Invenção: **20** anos - Modelo: **15** anos - Desenho industrial: **10** anos	Contados da data do depósito
- Marca: **10** anos	Contados da data da concessão

Quais prazos podem ser prorrogados e quais não são prorrogáveis?

A invenção e o modelo são **improrrogáveis**. Eles não admitem prorrogação. Acabada a patente, esta não pode ser prorrogada, caindo em domínio público. Portanto, **patente é improrrogável**.

O registro, por sua vez, admite prorrogação.

No caso do desenho industrial, ele pode ser prorrogado por até 3 vezes. Expirado o prazo da terceira prorrogação, também cairá em domínio público.

No caso da marca, ela não tem limite de prorrogação. A prorrogação se dá de 10 em 10 anos.

4.5.5. Invenção

Não há um conceito da invenção, nem doutrinário nem legal. A lei não diz o que é invenção, mas diz o que **não se considera invenção**, a saber:

> Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;II - concepções puramente abstratas;III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;V - programas de computador em si;VI - apresentação de informações;VII - regras de jogo;VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

4.5.5.1. REQUISITOS DA INVENÇÃO

a) Novidade

> Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

Novidade é aquilo que **não está compreendido no estado da técnica**.

É preciso saber então se esse invento **já existe, ou não,** no estágio atual da técnica.

b) Atividade Inventiva

> Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Considera-se atividade inventiva sempre que, para um especialista no assunto, **não decorra de**

maneira óbvia ou evidente do estado da técnica.

Estado da técnica: todos os conhecimentos a que pode ter acesso qualquer pessoa, especialmente os estudiosos de um assunto, no Brasil ou no exterior.

c) Aplicação Industrial

Só podemos patentear invenção que permite a industrialização.

d) Ausência de impedimento legal

Os casos de impedimento previstos em lei estão todos no art. 18, LPI.

> Art. 18. Não são patenteáveis:
> I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;
> II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e
> III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.
> Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

4.5.6. Modelo de Utilidade

A lei, nesse caso, diferentemente do que ocorre com a invenção, dá um conceito para o modelo de utilidade. Esse conceito está no art. 9º da LPI:

> Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Modelo de utilidade é, pois, o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, e resulte em **melhoria funcional** no seu uso ou em sua fabricação.

OBS: o modelo de utilidade gera uma funcionalidade maior para um invento já existente. EX: churrasqueira sem fumaça (a churrasqueira já existe – é uma invenção; o mecanismo criado para não provocar fumaça é que é um modelo de utilidade).

4.5.7. Desenho Industrial

Também é conceituado pela lei de propriedade industrial, em seu art. 95:

> Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um

> objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

A doutrina deu um apelido para o desenho industrial: “elemento fútil”, vez que não traz nenhum tipo de utilidade ou melhoria, preocupando-se apenas com a estética. EX: Preservativo colorido é desenho industrial. Com sabor, trata-se de modelo de utilidade.

4.5.8. Marca

O conceito de marca se encontra no art. 122, LPI:

> Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os **sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais**.

a) Espécies de Marca

Temos apenas 3 espécies de marca. Todas estão previstas no art. 123, da LPI, a saber:

> Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
> I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;
> II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e
> III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

b) Requisitos da Marca

b.1) Novidade: trata-se de uma novidade **relativa**.

Quando se analisa a novidade, é preciso analisar, também, a especificidade, ou seja, a classe específica daquele determinado bem, o seu ramo de atividade. EX: se já existe a marca Sol para massa de bolo, então não é mais possível ser criada outra marca idêntica nesse mesmo ramo de atividade. Mas pode ser possível a criação da mesma marca em outro ramo de atividade.

b) Ausência de impedimento legal – os casos de impedimento legal estão previstos no art. 124, LPI, quais sejam:

> Art. 124. Não são registráveis como marca:
> I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;
> II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
> III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;
V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;
VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;
VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;
IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;
X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;
XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;
XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;
XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;
XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;
XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;
XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;
XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;
XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;
XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

> XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

c) Não colidência com marca notória: não pode conflitar com uma marca notória.

Marca notória é aquela ostensivamente pública e conhecida, de popularidade internacional e que independe de registro no INPI para ter proteção legal.

OBS: marca notória é diferente de marca de alto renome. A marca notória é protegida, mas **dentro do seu ramo de atividade**. EX: Casas Bahia não é marca notória, mas ela pode pedir reconhecimento como marca de alto renome, fazendo o registro, e, então, poderá ter proteção **em todos os ramos de atividade**.

Marca notória – art. 126	Alto renome – art.. 125
- Só tem proteção no ramo de atividade;	- Tem proteção em todos os ramos de atividade;
- Não precisa de registro para ser protegida;	- Precisa de registro;
- Tem que ter reconhecimento internacional. Todos os países signatários do acordo.	- Tem reconhecimento no país.

4.5.7. Formas de Extinção da Propriedade Industrial

a) Expiração do prazo de vigência (ausência de renovação)

b) Renúncia do titular;

c) Falta de pagamento da retribuição anual; (não pagamento da taxa do INPI)

d) Caducidade (marca não utilizada por mais de cinco anos, sofre caducidade.

e) Inobservância do art. 217, LPI:

> Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

4.6. Questões

1ª) Diferencie a teoria dos atos de comércio e a teoria da empresa.

2ª) Quais os agentes econômicos excluídos do conceito de empresário? Fundamente.

3ª) Qual as principais características de uma sociedade limitada? Fundamente.

4ª) O que são valores mobiliários? Qual sua importância para as sociedades anônimas? Justifique e fundamente.

5ª) Faça uma breve dissertação sobre os bens protegidos pela lei de propriedade industrial e suas principais características.

5. Direito Civil

Bibliografia indicada

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito Civil Esquematizado. v. 1.** São Paulo: Saraiva, 2011.

TARTUCE, Flávio. **Direito Civil:** Parte geral. Série concursos públicos. São Paulo: Editora Método, 2011.

Legislação indicada

Código Civil

5.1. Parte Geral

5.1.1. Das pessoas

5.1.1.1. PERSONALIDADE JURÍDICA

Personalidade é a **aptidão genérica para titularizar direitos e contrair obrigações**, ou seja, é a **qualidade para ser sujeito de direitos**. São dotadas de personalidade jurídica as pessoas físicas e jurídicas.

5.1.1.2. PESSOA FÍSICA OU NATURAL

É denominada por Teixeira de Freitas como **ente de existência visível**. De acordo com o artigo 2º do Código Civil, a pessoa física **adquire personalidade jurídica** a partir do **nascimento com vida**.

5.1.1.3. CAPACIDADE JURÍDICA

Desdobra-se em **capacidade de direito** e **capacidade de fato (de exercício)**. A soma de ambas constitui a **capacidade civil plena**, que, regra geral, adquire-se aos 18 anos.

Capacidade de direito: Trata-se da **capacidade jurídica genérica**, que toda pessoa tem. Segundo Orlando Gomes, nos dias atuais, **a capacidade de direito confunde-se com a personalidade jurídica**.

Capacidade de fato: Consiste na **capacidade de exercer, por si, os atos da vida civil**. Nem todas as pessoas têm. Quando ausente, gera a incapacidade do indivíduo, que pode ser **relativa ou absoluta**, como exposto *infra*.

5.1.1.4. INCAPACIDADE ABSOLUTA (art. 3º do Código Civil)

Os atos praticados por absolutamente incapazes **são nulos de pleno direito**, não gerando qualquer efeito jurídico (artigo 166, I, do Código Civil).

Os absolutamente incapazes devem ser devidamente **representados** na praticados de todos os atos da vida civil**.** De acordo com o artigo 3º do Código Civil, são absolutamente incapazes:

a) **os menores de 16 anos**, chamados de menores impúberes;

b) aqueles que não tiverem o necessário discernimento para prática de atos da vida civil, em razão de **enfermidade ou deficiência mental;**

c) Aqueles que mesmo por causa transitória não puderem exprimir sua vontade; ATENÇÃO: Esta pessoa não é doente mental, mas **vítima de uma causa exógena** (EX: Indivíduo que entrou em coma após um acidente de carro). Trata-se de uma incapacidade absoluta, ainda que sua causa seja transitória.

5.1.1.5. INCAPACIDADE RELATIVA (artigo 4º do Código Civil)

Os atos praticados por relativamente incapazes **são anuláveis (artigo 171, I**, do Código Civil e podem vir a gerar efeitos jurídicos.

Os relativamente incapazes devem ser devidamente **assistidos** na prática de todos os atos da vida civil**.** De acordo com o artigo 4º do Código Civil, são absolutamente incapazes:

a) Maiores de 16 anos e menores de 18 anos: menores púberes;

b) Ébrios habituais, viciados em tóxicos, ou aqueles que por deficiência mental tenham discernimento reduzido.

Observe-se que, nessa hipótese, o discernimento é **reduzido**. Caso haja hipótese de ausência de discernimento, **em qualquer desses casos**, haverá incapacidade absoluta. Ex. embriaguez patológica gera incapacidade absoluta.

c) Excepcionais sem desenvolvimento mental completo.

d) Pródigos.

Tratamento jurídico do índio: Nos termos do parágrafo único do art. 4º, do CC/02, a capacidade do índio deve ser tratada em Lei especial (Lei 6.001/73 – Estatuto do Índio).

5.1.1.6. EMANCIPAÇÃO

Aos 18 anos completos é atingida a maioridade civil e a **capacidade civil plena**. Todavia, a capacidade civil poderá ser antecipada, mediante **emancipação**, nos termos do parágrafo único do art. 5º, a saber:

> Art. 5º A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil.
>
> **Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade:**
>
> I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos;
>
> II - pelo casamento;
>
> III - pelo exercício de emprego público efetivo;
>
> IV - pela colação de grau em curso de ensino superior;
>
> V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha economia própria.

ESPÉCIES DE EMANCIPAÇÃO

a) Voluntária – art. 5º, parágrafo único, inciso I, 1ª parte, do Código Civil:

É aquela concedida por ato dos pais, ou por um deles, na falta do outro, mediante instrumento público, em caráter irrevogável, independentemente de homologação judicial, desde que o menor tenha pelo menos 16 anos completos.

b) Judicial – art. 5º, parágrafo único, inciso I, 2ª parte, do Código Civil:

Determinada pelo juiz, ouvido o tutor, desde que o menor tenha 16 anos completos. **Esta espécie refere-se ao menor sob tutela.**

A tutela ocorre na ausência dos pais (falecidos) ou quando estes forem destituídos do Poder familiar.

c) Legal – art. 5º, parágrafo único, incisos II a V, do Código Civil:

No que tange a emancipação legal, existe mais de uma hipótese, quais sejam:

Casamento: De acordo com o Código Civil, homens e mulheres podem se casar a partir dos 16 anos, exigindo-se autorização dos pais ou do juiz (suprimento de consentimento paterno).

ATENÇÃO: Mesmo que haja separação ou divórcio, a emancipação persiste.

Exercício de emprego público efetivo: É muito raro de acontecer, pois os editais dos concursos, em geral, exigem 18 anos completos.

Colação de Grau em Curso de Ensino Superior: Também é bastante raro, mas pode ocorrer em casos excepcionais.

Estabelecimento civil, comercial ou relação de emprego, desde que o menor, com 16 anos completos, em função deles, tenha economia própria: mesmo que venha a perder o emprego, o menor emancipado **não retornará a situação de incapacidade**.

5.1.1.7. EXTINÇÃO DA PESSOA NATURAL

A morte marca o fim da pessoa natural, nos termos do art. 6º do CC, a saber: “A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva”.

O óbito deve ser declarado por médico ou, no caso de ausência de profissional capacitado no local, por duas testemunhas que possam fazê-lo. O registro é feito no livro de óbito (art. 77, da Lei de Registros Públicos).

Morte Presumida: O Código Civil Brasileiro, art. 6º, 2ª parte, e art. 7º, estabelece duas situações de morte presumida, quais sejam: a) decorrente da ausência; b) sem o procedimento da ausência.

Ausência consiste na situação em que uma pessoa desaparece de seu domicílio sem deixar notícias ou representante que administre seu patrimônio. Os artigos 22 e seguintes estabelecem o procedimento de transmissibilidade dos bens no caso em comento.

Haverá morte presumida **sem declaração de ausência** nas hipóteses do art. 7º do Código Civil, mediante procedimento de justificação. Nesses casos, há fundado indício de que houve a morte, mas

não há cadáver. A sentença proferida, que indicará data provável da morte (procedimento de justificação), será registrada no livro de óbito normal. Eis as hipóteses:

> Art. 7º Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência:
>
> I - se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida;
>
> II - se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o término da guerra.
>
> Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento.

5.1.1.8. PESSOA JURÍDICA

a) Conceito

Pessoa jurídica pode ser definida como um **grupo humano criado, na forma da lei, com personalidade jurídica própria para a realização de determinados fins**. Enfim, trata-se de um grupo humano personificado pelo direito em sua essência.

b) Surgimento da Pessoa Jurídica

A pessoa jurídica é constituída **a partir de sua inscrição no registro competente**.

A pessoa jurídica só passa a ter existência legal com o registro no de seu ato constitutivo.

Em geral, o registro público competente é a Junta Comercial ou o Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

c) Principais Espécies de Pessoa jurídica no Direito Privado:

O Código Civil, na redação original do art. 44 estabelecia três espécies básicas de pessoas jurídicas de direito privado: associações, sociedades e fundações. Na redação atual, acrescentaram-se dois incisos para incluir as organizações religiosas e os partidos políticos, que são essencialmente associações.

d) Fundação: Trata-se de uma pessoa jurídica que não resulta da união de indivíduos, mas da **afetação de um patrimônio**, que se personifica, mediante a manifestação de vontade do instituidor para a realização de fins ideais, nos termos do art. 62 do Código Civil.

A fundação **não pode ter fins lucrativos** e **só pode ser criada por escritura pública ou testamento**.

Em suma, a fundação é a personificação de um patrimônio.

e) Sociedades: São pessoas jurídicas de direito privado, dotadas de personalidade jurídica própria e instituídas por meio de contrato social visam à finalidade econômica – art. 981, CC. Tal entidade visa lucro, essencialmente.

Constituem um dos objetos de estudo do Direito Empresarial.

f) Associações: Formam-se pela união de indivíduos com propósito de realizarem fins não econômicos (art. 53, CC). Não há finalidade de partilha de lucro. Ex. associação de bairro, clubes,

sindicatos.

> Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos.
> Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos.

g) Extinção da Pessoa Jurídica – Fundamentalmente existem três formas de extinção da pessoa jurídica, a saber:

Convencional: os próprios sócios ou administradores deliberam a extinção da pessoa jurídica. É mais comum para as sociedades (Distrato).

Administrativa: resulta da cassação da autorização específica de constituição e funcionamento da pessoa jurídica.

Judicial: é aquela que se opera por meio de sentença, a exemplo do que se dá no procedimento de falência.

5.1.1.9. DOMICÍLIO

a) Morada x residência x domicílio

Morada: é simplesmente o lugar em que a pessoa física se estabelece temporariamente. É provisória. Não altera nem modifica o domicílio e a residência.

Residência: pressupõe estabilidade – é o lugar em que a pessoa física se estabelece habitualmente. É estável, habitual. É sede estável da pessoa.

Domicílio: é o conceito mais abrangente, uma vez que traduz o lugar em que a pessoa física se estabelece com ânimo definitivo *(Animus manendi),* convertendo-o em centro principal de sua vida jurídica.

b) Conceito:

> Art. 70, CC. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo.

Caso a pessoa tenha mais de uma cidade/lugar como centro de sua vida jurídica, pode ter mais de um domicílio, segundo o art. 71, CC.

> Art. 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas.

O CC Brasileiro, em seu art. 72, consagra, para determinados efeitos, um DOMICÍLIO PROFISSIONAL. Não se trata de domicílio especial – quanto às relações concernentes à profissão. Caso o agente tenha atividade em mais de um lugar, cada um deles será seu domicílio.

No que se refere a **mudança de domicílio**, a matéria é tratada no art. 74 do CC.

> Art. 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida.
> Parágrafo único. Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem.

> Art. 74. Muda-se o domicílio, transferindo a residência, com a intenção manifesta de o mudar.
> Parágrafo único. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa às municipalidades dos lugares, que deixa, e para onde vai, ou, se tais declarações não fizer, da própria mudança, com as circunstâncias que a acompanharem.

O **domicílio da pessoa jurídica** é regulado no art. 75 do CC.

> Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é:
> I - da União, o Distrito Federal;
> II - dos Estados e Territórios, as respectivas capitais;
> III - do Município, o lugar onde funcione a administração municipal;
> IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos.
> § 1º Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados.
> § 2º Se a administração, ou diretoria, tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento, sito no Brasil, a que ela corresponder.

Domicílio Aparente ou ocasional: trata-se de uma ficção jurídica baseada na teoria da aparência. De acordo art. 73 do CC, para pessoas que não têm domicílio certo, como circenses, considera-se domicílio o local em que forem encontradas.

> Art. 73. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que não tenha residência habitual, o lugar onde for encontrada.

c) Espécies de Domicílio:

Convencional ou voluntário: é o mais comum, fixado por simples ato de vontade, segundo a autonomia privada.

Especial ou de eleição: regulado nos artigos 78 do CC. Trata-se de domicílio escolhido pelas próprias partes no contrato.

> Art. 78. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes.

De acordo com o princípio da função social, nos termos do art. 112, parágrafo único do CPC, a nulidade de cláusula de eleição de foro, especialmente em contratos de consumo pode ser declarada de ofício pelo juiz, sem necessidade de requerimento da parte.

Legal: arts. 76 e 77 do CC.

Incapaz – domicílio de seu representante;
Servidor público – onde exerce função permanente;
Militar do exército – onde servir;
Militar da aeronáutica ou marinha – sede de seu comando;
Marítimo (marinha mercante) – onde o navio estiver matriculado;
Preso – onde cumprir pena (sentença)

> Art. 76. Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso.
> Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente; o do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções; o do militar, onde servir, e, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado; o do marítimo, onde o navio estiver matriculado; e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença.

5.1.2. Dos bens

a) Conceito: Bem jurídico é **toda utilidade física ou ideal** objeto de um direito subjetivo.

b) Classificação dos bens jurídicos:

b.1) BENS CONSIDERADOS EM SI MESMO

Bens imóveis – são aqueles que não podem ser transportados de um lugar para outro sem alteração de sua substância (um terreno).

Bens móveis – são os passíveis de deslocamento, sem quebra ou fratura (um computador, v.g.). Os bens suscetíveis de movimento próprio, enquadráveis na noção de móveis, são chamados de semoventes (um cachorro, v.g.).

> Art. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Art. 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais: I – os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram; II – o direito à sucessão aberta. OBS.: Importantes efeitos derivam da natureza imobiliária do "direito à sucessão aberta", a exemplo da necessidade, apontada por parcela respeitável da doutrina, de se exigir a autorização do cônjuge do renunciante, no bojo do inventário, por se considerar que a renúncia, no caso, opera-se de forma semelhante à alienação de um imóvel, exigindo-se a vênia daqueles que não casaram no regime da separação absoluta de bens (art. 1647). Sobre o tema, tivemos a oportunidade de escrever:

Bens fungíveis – são aqueles que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade (dinheiro por ex.). Bens infungíveis – por sua vez, são aqueles de natureza insubstituível. Exemplo: uma obra de arte.

> Art. 85. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade.

Bens consumíveis – são os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da própria substância, bem como aqueles destinados à alienação (um sanduíche).

Bens inconsumíveis – são aqueles que suportam uso continuado (um avião, um carro).

Art. 86. São consumíveis os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação.

Bens divisíveis – são os que se podem repartir em porções reais e distintas, formando cada uma delas um todo perfeito (uma saca de café). Bens indivisíveis – não admitem divisão cômoda sem desvalorização ou dano (um cavalo).

Art. 87. Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destinam.
Art. 88. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes.

Bens singulares – são coisas consideradas em sua individualidade, representadas por uma unidade autônoma e, por isso, distinta de quaisquer outras (um lápis, um livro).

Bens coletivos ou universalidades – são aqueles que, em conjunto, formam um todo homogêneo (universalidade da fato – um rebanho, uma biblioteca; universalidade de direito – o patrimônio, a herança).

Art. 89. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, independentemente dos demais.
Art. 90. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária.
Parágrafo único. Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias.
Art. 91. Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas, de uma pessoa, dotadas de valor econômico.

b.2) BENS RECIPROCAMENTE CONSIDERADOS

Principal - é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente (a árvore em relação ao fruto).

Acessório – é o bem cuja existência supõe a do principal (fruto em relação à árvore)

São bens acessórios:

Os frutos – trata-se das utilidades renováveis, ou seja, que a coisa principal periodicamente produz, e cuja percepção não diminui a sua substância (café, soja, laranja).

Classificam-se em:

Quanto à sua natureza:

Naturais – são gerados pelo bem principal sem necessidade da intervenção humana direta (laranja, café);

Industriais – são decorrentes da atividade industrial humana (bens manufaturados);

Civis – são utilidades que a coisa frugífera periodicamente produz, viabilizando a percepção de uma renda (juros, aluguel).

Quanto à ligação com a coisa principal:
Colhidos ou percebidos – são os frutos já destacados da coisa principal, mas ainda existentes;

Pendentes – são aqueles que ainda se encontram ligados à coisa principal, não tendo sido, portanto, destacados;

Percipiendos – são aqueles que deveriam ter sido colhidos mas não o foram;

Estantes – são os frutos já destacados, que se encontram estocados e armazenados para a venda;

Consumidos: que não mais existem.

Os produtos – trata-se de utilidades não-renováveis, cuja percepção diminui a substância da coisa principal (carvão extraído de uma mina esgotável).

Os rendimentos - são frutos civis, como os juros e o aluguel.

As pertenças – trata-se das coisas que, sem integrarem a coisa principal, facilitam a sua utilização, a exemplo do aparelho de ar condicionado (art. 93 do CC).

As benfeitorias – trata-se de toda obra realizada pelo homem na estrutura de uma coisa, com o propósito de conservá-la (benfeitoria necessária – ex.: reforma em uma viga), melhorá-la (benfeitoria útil – abertura do vão de entrada da casa) ou embelezá-la (benfeitoria voluptuária – uma escultura talhada na parede de pedra do imóvel). Ver arts. 96 e 97 do CC.

As partes integrantes – integra a coisa principal de maneira que a sua separação prejudicará a fruição do todo, ou seja, a utilização do bem jurídico principal (ex.: a lâmpada em relação ao lustre).

b.3) BENS PÚBLICOS E PARTICULARES

Quanto ao titular do domínio, os bens poderão ser públicos (uso comum do povo, uso especial e dominiais) ou particulares. Os bens públicos são estudados pelo Direito Administrativo.

Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem.
Art. 99. São bens públicos:
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;
II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias;
III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.
Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado.
Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar.
Art. 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as

> exigências da lei.
> Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. Art. 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem.

Demais classificações:

Imóveis por força de lei: esta figura se encontra disciplinada no art. 80 do CC, no qual o próprio legislador determina a natureza imobiliária.

> Art. 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais:
> I - os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram;
> II - o direito à sucessão aberta.

Bens duráveis e não duráveis: o CDC adota, em seu art. 66, uma classificação de bens que não consagrada no CC. O diploma faz uma distinção entre bens **duráveis e não duráveis** para efeito de se reclamar por **vício de qualidade**.

5.1.3 Dos fatos, atos e negócios jurídicos

5.1.3.1. FATO JURÍDICO

a) Conceito: Fato jurídico é todo acontecimento natural ou humano apto a criar, modificar ou extinguir relações jurídicas. Para que um fato seja jurídico, este deve ter relevância para o direito.

b) Fato jurídico em sentido Estrito: Seja ordinário ou extraordinário é todo acontecimento natural deflagrador de efeitos jurídicos. É acontecimento alheio a vontade do homem.

Pode ser comum, corriqueiro, ordinário. Ex. Chuva de verão – que faz desabar uma casa; o nascimento de uma criança, decurso do tempo = são fatos jurídicos em sentido estrito – são comuns e deflagram efeitos na órbita do direito.

Pode ainda ser extraordinário. Ex. furação no litoral do Ceará.

c) Ações Humanas: Sejam lícitas ou ilícitas, as ações humanas são espécies de fatos jurídicos.

As ações humanas ilícitas estão consagradas nos artigos 186 a 188 e artigos 927 e seguintes, do CC, e são objeto de estudo da responsabilidade civil.

Já as ações humanas lícitas subdividem-se em duas espécies: ato jurídico em sentido estrito e negócio jurídico.

d) Ações Humanas Lícitas:

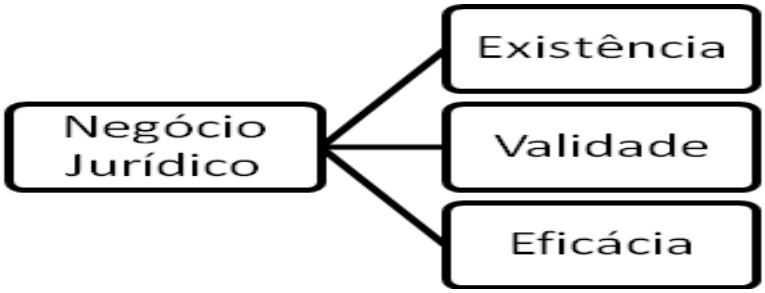
d.1) Ato jurídico em sentido estrito: Também denominado de ato não negocial, traduz um simples comportamento humano, voluntário e consciente, cujos efeitos jurídicos estão previamente determinados na lei. Não existe aqui, liberdade de escolha dos efeitos jurídicos alcançados. Seus efeitos estão delineados na lei, não havendo liberdade de escolha quanto aos efeitos.

d.2) Negocio jurídico:

O negocio jurídico, por sua vez, não é um simples comportamento humano, mas sim uma declaração de vontade emitida segundo o princípio da autonomia privada, pela qual o declarante, nos limites da função social e da boa-fé objetiva visa a atingir efeitos jurídicos escolhidos e possíveis.

No negócio jurídico há autonomia que não existe no ato jurídico em sentido estrito. EX: contrato, testamento (ainda que limitado pela legítima, não há autonomia).

Planos de caracterização do Negócio Jurídico



EXISTÊNCIA: É plano substantivo do Negócio Jurídico, em que se estudam os pressupostos existenciais do negócio – elementos constitutivos do negócio, sem os quais este não existirá.

São pressupostos de existência do negócio jurídico:

Manifestação da vontade: se não há vontade não há negócio jurídico. OBS: Havendo coação física, não há vontade, e, via de conseqüência, não haverá negócio jurídico.

Agente: emissor da vontade. Em regra, é pessoa física ou jurídica.

Objeto: sobre o qual incide o negócio. Bem jurídico ou prestação.

Forma: Vicente Ráo reconhece a forma como elemento existencial do negócio. Trata-se do meio pelo qual a vontade se manifesta (escrita, verbal, mímica) e, excepcionado o caso do silêncio, é sempre exigida. A forma é o revestimento exterior da vontade.

VALIDADE: O art. 104, CC traz os pressupostos de validade do Negócio Jurídico.

> Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:
> I - agente capaz;
> II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
> III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Pressupostos:

Vontade **livre e de boa-fé** (segundo a maioria doutrina, trata-se de um pressuposto, apesar de não estar disposto em lei);

Agente **capaz e legitimado**;

Objeto **lícito, possível, determinado ou determinável**.

Forma **livre ou prescrita em lei**.

Há, pois, a **complementação dos pressupostos de existência**.

No que tange a forma, merece ressaltar que vigora no Brasil, nos termos do art. 107 do CC o princípio vigente é o da liberdade da forma, e, em regra, os negócios jurídicos têm forma livre.

Todavia, a própria lei (art. 227, CC) pode exigir forma prescrita par efeito de prova do negócio jurídico (Negócio *Ad Probationem).*

Além disso, pode-se exigir forma também como requisito de validade do próprio negócio (art. 108, CC): nesse caso, temos um negócio *Ad solemnitatem.*

Citem-se os dispositivos pertinentes:

> Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.
> Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.
> Art. 109. No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato.

EFICÁCIA

É estudada junto aos elementos que interferem na eficácia do negócio jurídico, quais sejam: condição, termo e encargo.

Modo ou encargo: Trata-se de uma determinação acessória típica dos negócios jurídicos gratuitos, por meio da qual é imposto à parte um ônus em prol de um benefício maior. EX: doação da fazenda sob o encargo do donatário efetivar a doação de cinco cestas básicas para uma creche, durante doze meses.

No CC, o encargo é disciplinado em apenas dois artigos: 136 e 137.

> Art. 136. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico, pelo disponente, como condição suspensiva.
> Art. 137. Considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade, caso em que se invalida o negócio jurídico.

A regra é de que o encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito.

Condição: Condição, **elemento acidental do negócio jurídico**, consiste no acontecimento **futuro e incerto** que suspende ou resolve a eficácia jurídica do negócio.

Observe-se que a cláusula que estipula condição é sempre convencionada pelas partes (art. 121), não ser determinada por lei (*condiciones iuris)*.

CONDIÇÃO SUSPENSIVA X CONDIÇÃO RESOLUTIVA

Suspensiva: a condição suspensiva é o acontecimento futuro e incerto que suspende o início da eficácia jurídica do negócio. Ex. doarei um carro quando casar.

Resolutiva: resolve ou desfaz, quando implementada, os efeitos jurídicos até então produzidos

pelo negócio. A sua disciplina, na parte geral, é feita nos arts. 127 e 128 do CC. Ex. receberá uma renda até que passe em um concurso.

Termo: O termo, diferentemente da condição, é o acontecimento futuro e certo que interfere no início ou fim da eficácia jurídica do negócio. Está previsto nos arts. 131 e ss. do CC.

> Art. 131. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito.
> Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento.
> § 1º Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil.
> § 2º Meado considera-se, em qualquer mês, o seu décimo quinto dia.
> § 3º Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência.
> § 4º Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto.
> Art. 133. Nos testamentos, presume-se o prazo em favor do herdeiro, e, nos contratos, em proveito do devedor, salvo, quanto a esses, se do teor do instrumento, ou das circunstâncias, resultar que se estabeleceu a benefício do credor, ou de ambos os contratantes.
> Art. 134. Os negócios jurídicos entre vivos, sem prazo, são exeqüíveis desde logo, salvo se a execução tiver de ser feita em lugar diverso ou depender de tempo.
> Art. 135. Ao termo inicial e final aplicam-se, no que couber, as disposições relativas à condição suspensiva e resolutiva.

INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO

O reconhecimento da invalidade de um ato é uma **forma de defesa do ordenamento jurídico**.

Invalidade é um conceito genérico do qual se desdobram **nulidade absoluta e nulidade relativa (anulabilidade).**

OBS: A regra é tentar salvar o negócio. O intérprete deve tentar, como diretriz de sua atividade hermenêutica, sempre que possível, conservar o negócio jurídico inválido, a exemplo do que se dá por meio de sua redução (art. 184, CC).

> Art. 184, CC: a invalidade da obrigação principal importa na da acessória, mas a recíproca não é verdadeira.

Nulidade absoluta: Estão previstas nos artigos 166 e 167. Segundo esses dispositivos, o negócio jurídico é nulo quando:

Celebrado por pessoa **absolutamente incapaz**;

Por **ilícito, impossível, ou indeterminável seu objeto**;

O **motivo determinante**, comum a ambas as partes for **ilícito** (refere-se à finalidade ou causa do negócio).

> Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:
> I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;
> II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

> III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;
> IV - não revestir a forma prescrita em lei;
> V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;
> VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;
> VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.
> Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.
> § 1º Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
> I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;
> II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
> III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
> § 2º Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.
> Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir.
> Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes.
> Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.
> Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.

NULIDADE RELATIVA

A sua base se encontra no art. 171 do CC.

A nulidade relativa é menos grave.

Dispõe o art. 171 do CC (cujo rol é exemplificativo) que, além dos casos expressamente declarados em lei, é anulável o negócio jurídico:

Por **incapacidade relativa** do agente;

Vício resultante de **erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores**.

> Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:
> I - por incapacidade relativa do agente;
> II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Demais dispositivos atinentes à nulidade relativa:

> Art. 172. O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro.

Art. 173. O ato de confirmação deve conter a substância do negócio celebrado e a vontade expressa de mantê-lo.
Art. 174. É escusada a confirmação expressa, quando o negócio já foi cumprido em parte pelo devedor, ciente do vício que o inquinava.
Art. 175. A confirmação expressa, ou a execução voluntária de negócio anulável, nos termos dos arts. 172 a 174, importa a extinção de todas as ações, ou exceções, de que contra ele dispusesse o devedor.
Art. 176. Quando a anulabilidade do ato resultar da falta de autorização de terceiro, será validado se este a der posteriormente.
Art. 177. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício; só os interessados a podem alegar, e aproveita exclusivamente aos que a alegarem, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade.
Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:
I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;
II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;
III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.
Art. 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato.
Art. 180. O menor, entre dezesseis e dezoito anos, não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior.
Art. 181. Ninguém pode reclamar o que, por uma obrigação anulada, pagou a um incapaz, se não provar que reverteu em proveito dele a importância paga.
Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.
Art. 183. A invalidade do instrumento não induz a do negócio jurídico sempre que este puder provar-se por outro meio.
Art. 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável; a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal.

5.1.4. Prescrição e decadência

5.1.4.1 PRESCRIÇÃO: É a perda do direito de pretensão, que nasce a partir da violação de direito. Em linhas gerais, tem-se a prescrição quando o indivíduo é frustrado em sua seara jurídica, e, tendo um prazo para fazer jus a seus direitos subjetivo, queda inerte.

Citem-se os **dispositivos gerais sobre prescrição**:

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.
Art. 190. A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão.

> Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.
> Art. 192. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes.
> Art. 193. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita.
> ~~Art. 194. O juiz não pode suprir, de ofício, a alegação de prescrição, salvo se favorecer a absolutamente incapaz.~~ (Revogado pela Lei nº 11.280, de 2006)
> Art. 195. Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais, que derem causa à prescrição, ou não a alegarem oportunamente.
> Art. 196. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor.

5.1.4.2. Decadência:

A decadência, também chamada de caducidade, nada tem haver com o direito a pretensão. Refere-se a direitos potestativos.

Por direito potestativo entenda-se aquele que, sem o conteúdo prestacional, interfere na esfera jurídica alheia, sem que essa pessoa nada possa fazer.

EX: divórcio, renúncia ao mandato.

OBS: Diferentemente dos prazos prescricionais que sempre estão previstos em lei, os prazos decadenciais podem ser legais ou convencionais (avençados pelas partes).

Citem-se os dispositivos gerais da decadência:

> Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.
> Art. 208. Aplica-se à decadência o disposto nos arts. 195 e 198, inciso I.
> Art. 209. É nula a renúncia à decadência fixada em lei.
> Art. 210. Deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência, quando estabelecida por lei.
> Art. 211. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação.

5.2. Questões

1ª) A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. De acordo com o Código Civil Brasileiro, cessará, para os menores, a incapacidade

a) pelo exercício de emprego público temporário.

b) pela concessão dos pais, se o menor tiver quatorze anos completos.

c) pelo casamento.

d) pela colação de grau em curso de ensino médio.

e) pela aquisição de imóvel.

2ª) Sobre o domicílio da pessoa natural e da pessoa jurídica, é correto afirmar:

a) O domicílio do marítimo é o de onde o navio estiver ancorado.

b) O domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual, será o lugar do último endereço declarado.

c) Quanto às relações concernentes à profissão, domicílio da pessoa natural é o lugar da sede principal da pessoa jurídica para a qual trabalhe.

d) Se a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternativamente, viva, considerar-se-á domicílio qualquer delas.

e) Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, o domicílio será, sempre, o local da sede principal da pessoa jurídica.

3ª) João, casado com Dora, possui quatro filhos: Ana, Fábio, Douglas e Mônica. Ana possui dezesseis anos e cinco meses; Fábio possui dezenove anos, mas é pródigo; Douglas possui vinte anos, mas é excepcional, sem desenvolvimento mental completo e Mônica possui vinte e cinco anos, mas, em razão de causa transitória, não pode exprimir a sua vontade. Nesta família, são incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer

a) Ana, Fábio e Douglas.

b) Ana e Fábio.

c) Ana, apenas.

d) Fábio e Mônica.

e) Ana e Mônica.

4ª) O que são bens reciprocamente considerados? Responda expondo as classificações atinentes.

5ª) Diferencie condição suspensiva de condição resolutiva.

6ª) O que são direitos potestativos? Estão relacionados com prescrição ou decadência? Fundamente.

Gab: 1. C; 2. D; 3. A;

6. Direito do Consumidor

Bibliografia indicada

GARCIA, Leonardo Medeiros de. **Direito do consumidor:** código comentado e jurisprudência**.** Niterói: Editora Impetus, 2011.

Legislação indicada

Código de defesa do consumidor

6.1. Dos direitos básicos do consumidor – artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor

Ao elencar os direitos do consumidor, o legislador fez questão de ressaltar que se tratam dos direitos básicos, ou seja, aqueles que irão servir de base na orientação e instrumentalização das relações de consumo.

Não há dúvidas de que os consumidores possuem um número bem mais voluptuoso de direitos, que não foram elencados no artigo 6º, mas que, ainda assim, podem ser usados na defesa dos hipossuficientes.

Trata-se, portanto, de uma rol exemplificativo.

Eis a redação do dispositivo:

> Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
>
> I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;
>
> II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;
>
> III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
>
> IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
>
> V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;
>
> VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;
>
> VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;
>
> VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a

> alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
>
> IX - (Vetado);
>
> X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

6.2. Da qualidade de produtos e serviços, da prevenção e reparação de danos – artigo 8º a 27, do CDC;

6.2.1. Proteção à saúde e segurança

Os produtos e serviços oferecidos no mercado de consumo não podem acarretar riscos a saúde e à segurança dos consumidores, salvo aqueles que, pela sua própria natureza, apresentam em si um risco inerente – considerados pelo artigo 8º, do CDC, como “normais e previsíveis”. EX: Remédios, bebidas alcoólicas, agrotóxicos e fogos de artifício.

Consignem-se os dispositivos que tratam da matéria no Código de Defesa do Consumidor:

> Art. 8° Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.
>
> Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto.
>
> Art. 9° O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto.
>
> Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança.
>
> § 1° O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários.
>
> § 2° Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço.
>
> § 3° Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão informá-los a respeito.

6.2.2. Modelo de responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor

O Código de Defesa do Consumidor disciplina, nos artigos 12 a 17, a responsabilidade por vícios de segurança (sob o título “responsabilidade pelo fato do produto e do serviço”), em que a utilização do

produto ou serviço é capaz de gerar riscos à segurança do consumidor ou de terceiros, podendo ocasionar um evento danoso, denominado de “acidente de consumo”.

Por sua vez, os artigos 18 a 25, do mesmo diploma, preocupam-se com os vícios de adequação (sob o título “da responsabilidade por vício do produto e do serviço), em que os produtos ou serviços não correspondem às expectativas geradas pelo consumidor quando da utilização ou fruição, afetando, assim, a prestabilidade, tornando-se inadequados.

6.2.2.1. Responsabilidade pelo fato do produto e do serviço

> Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.
>
> § 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
>
> I - sua apresentação;
>
> II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
>
> III - a época em que foi colocado em circulação.
>
> §2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.
>
> §3º O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:
>
> I - que não colocou o produto no mercado;
>
> II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;
>
> III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
>
> Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:
>
> I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;
>
> II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;
>
> III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis.
>
> Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso.
>
> Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos

relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Art. 15. (Vetado).

Art. 16. (Vetado).

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

6.2.2.2. Responsabilidade pelo vício do produto e do serviço

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§2º Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.

§3º O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

§4º Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1° deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1° deste artigo.

§5º No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor.

§6º São impróprios ao uso e consumo:

I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;

II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;

III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.

Art. 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - o abatimento proporcional do preço;

II - complementação do peso ou medida;

III - a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios;

IV - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

§1° Aplica-se a este artigo o disposto no § 4° do artigo anterior.

§2° O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais.

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

> III - o abatimento proporcional do preço.
>
> § 1° A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor.
>
> § 2° São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.
>
> Art. 21. No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto a estes últimos, autorização em contrário do consumidor.
>
> Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
>
> Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.
>
> Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.
>
> Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.
>
> Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.
>
> § 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.
>
> § 2° Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação.

6.3. Das práticas abusivas

Não se permite, no ordenamento jurídico brasileiro, o exercício de direito de modo absoluto. O direito somente será reconhecido quando exercido de modo leal, não frustrando as legítimas expectativas criadas em outrem, sem desvio de finalidade. Caso contrário, será considerado ato ilícito ainda que o titular não ofenda a norma em si (legalidade estrita), mas ofenda a sua valoração.

A prática consumerista abusiva decorre desse exercício desleal fornecedor de produtos ou serviços, de modo a frustrar as expectativas do consumidores. Estas práticas estão enumeradas no artigo 39, que traz um rol meramente exemplificativo, a saber:

> Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

II - recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes;

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

VI - executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes;

VII - repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos;

VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);

~~IX - deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério;~~

IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais; (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

~~X - (Vetado).~~

X - elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. (Incluído pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

XI - Dispositivo incluído pela MPV nº 1.890-67, de 22.10.1999, transformado em inciso XIII, quando da converão na Lei nº 9.870, de 23.11.1999

XII - deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério.(Incluído pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)

XIII - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido. (Incluído pela Lei nº 9.870, de 23.11.1999)

Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento.

6.5. Da proteção contratual

A proteção contratual está presente nos artigos 46 a 55, do Código de Defesa do consumidor, e visam estabelecer uma série de prerrogativas ao hipossuficiente que firma contrato com pessoas jurídicas dotadas de maior poderio econômico.

É cediço que os contratos estipuladores de relações consumo, para ter validade e obrigar o consumidor, exigem que o fornecedor ofereça ao adquirente do produto ou serviço a oportunidade de tomar conhecimento efetivo de todos os direitos e deveres, principalmente no que se refere às **cláusulas restritivas em contratos de adesão** (aqueles que vêm pré-constituídos, sem possibilidade de alteração pela partes contratantes), **que, conforme o artigo 54, §4º, deverão ser redigidas em destaque, permitindo imediata compreensão.**

Atente-se para a redação dos dispositivos:

> CAPÍTULO VI
> Da Proteção Contratual
>
> SEÇÃO I
> Disposições Gerais
>
> Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.
>
> Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
>
> Art. 48. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos.
>
> Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.
>
> Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.
>
> Art. 50. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito.
>
> Parágrafo único. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso do produto em linguagem didática, com ilustrações.
>
> SEÇÃO II
> Das Cláusulas Abusivas

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

III - transfiram responsabilidades a terceiros;

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

V - (Vetado);

VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor;

VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem;

VIII - imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor;

IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor;

X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;

XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor;

XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;

XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração;

XIV - infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais;

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

XVI - possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias.

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vontade que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

§ 3° (Vetado).

§ 4° É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério Público que ajuíze a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual que contrarie o disposto neste código ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes.

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento.

~~§ 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigação no seu termo não poderão ser superiores a dez por cento do valor da prestação.~~

§ 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação. (Redação dada pela Lei nº 9.298, de 1º.8.1996)

§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

§ 3º (Vetado).

Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado.

§ 1° (Vetado).

§ 2º Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo.

§ 3° Os contratos de que trata o caput deste artigo serão expressos em moeda corrente nacional.

SEÇÃO III
Dos Contratos de Adesão

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de

produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 1° A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato.

§ 2° Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no § 2° do artigo anterior.

~~§ 3° Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.~~

§ 3º Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.(Redação dada pela nº 11.785, de 2008)

§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

§ 5° (Vetado)

6.6. Questões

1ª) Como se dá a proteção à saúde e à segurança no Direito do Consumidor.

2ª) Disserte sobre o modelo de responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

3ª) Faça um breve texto sobre os fundamentos de validade dos contratos de consumo.

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!

Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

Secretaria da Educação